

제5장 보전처분에 대한 채무자의 구제

제3면
제5장
제1절

제1절 총설

1. 총론

보전처분은 채무자를 심문하지 않고 채권자의 일방적 소명에 의하여 발령되는 경우도 있고, 채무자를 심문하였다 하더라도 일단 보전처분이 발령되면 채무자는 재산의 처분이 금지되거나 일정한 의무가 부과됨으로 인하여 큰 고통을 받게 된다. 따라서 법은 채무자의 이익보호를 위하여 각종의 구제절차를 마련하고 있는데, 이를 크게 보전처분신청 내지 보전처분의 당부를 재심사하는 이의절차와 보전처분의 당부를 심사하는 것이 아니라 현재 보전처분을 유지할 필요가 없게 되었다는 것을 이유로 그 취소를 구하는 취소절차로 나눌 수 있다. 두 절차 모두 보전처분의 유지 여부를 판단하는 절차임에는 같으나, 전자는 그 신청의 당부와 보전처분의 당부를 심리할 것을 요구할 수 있는 권리를 채무자에게 인정하는 제도임에 비하여, 후자는 보전처분의 당부는 일응 덮어두고 현재의 여러 가지 사정으로 볼 때 당사자 사이의 권리를 비교하면 보전처분을 유지하는 것이 부적당하다는 이유를 들어 채무자가 보전처분의 취소를 구하는 제도이다.

2. 보전처분에 대한 이의

이의절차는 보전처분에 대한 일종의 불복절차이며, 보전처분에 대하여 따로 불복절차가 마련되어 있으므로 명령에 대한 통상의 불복방법, 즉 항고나 재항고는 허용되지 않는다(대결 1991. 3. 29. 90마819, 대결 2008. 12. 22. 2008마1752 등). 또한 그 보전처분과 내용이 서로 저촉되는 제2의 보전처분을 받음으로써 사실상 선행의 보전처분을 폐지, 변경하거나

그 집행을 배제하는 목적을 달성하는 것은 허용되지 않는다(대결 1992. 6. 26. 92마401). 실무상 가압류명령에 대한 이의를 ‘가압류이의’, 가처분명령에 대한 이의를 ‘가처분이의’라고 하고, 이를 합하여 ‘보전처분이의’라고 한다. 보전처분에 대한 이의는 보전처분에 대한 불복절차로서 채무자의 신청에 의하여 절차가 개시되지만, 그 심리에서는 보전처분을 신청한 채권자가 적극적 당사자가 되고 채무자는 방어자의 입장에 서는 소극적 당사자가 된다.

3. 보전처분의 취소

취소절차는 일단 유효하게 발령된 보전처분을 새로운 재판에 의하여 실효시키고자 하는 것으로서 일종의 형성소송이다. 실무상 가압류명령의 취소를 ‘가압류취소’, 가처분명령의 취소를 ‘가처분취소’라고 하고, 이를 합하여 ‘보전처분취소’라고 한다. 그 취소사유로 법에 규정되어 있는 것은 ① 채권자가 본안의 제소명령을 기간 내에 이행하지 않은 경우(민집 287조 3항), ② 보전처분 후 사정의 변경이 있는 때(민집 288조 1항 1호), ③ 채무자가 법원이 명한 담보를 제공하는 경우(가압류에만 해당, 민집 288조 1항 2호), ④ 보전집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때(민집 288조 1항 3호), ⑤ 가처분에서 특별한 사정이 있을 때(민집 307조)이다. 취소신청은 보전처분신청에 대한 심리와는 별개 독립의 재판절차를 구하는 것이므로 취소절차에서의 적극적 당사자는 취소사유가 존재함을 주장하는 신청인(채무자)이고, 피신청인(채권자)은 소극적 당사자가 된다.

142 4. 보전처분이의와 보전처분취소의 관계

가. 보전이의절차에서 보전취소사유의 주장

보전이의는 심리종결 시를 기준으로 보전신청의 당부를 판단하는 절차이기 때문에 심리종결 시까지의 사정이 모두 이의사유가 될 수 있으므로(대판 1978. 2. 14. 77다938), 채무자는 사정변경에 해당하는 사유(대판 1981. 9. 22. 81다638), 특별사정의 존재 및 제소기간의 경과(대판 2000. 2. 11. 99다50064), 보전처분 이후 3년간 본안의 소를 제기하지 않은 경우(대결 2018. 10. 4. 2017마6308) 등 보전취소사유도 이의절차에서 항변사유로 주장할 수 있다. 그러나 담보제공에 의한 가압류취소제도상의 담보는 채권자에게 질권자와 동일한 효력을 부여하는 것으로, 보전이의에서 명하는 담보와 성질을 달리하므로 보전이의사유로 주장할 수 없다.

나. 이의절차와 취소절차의 경합

통설과 실무는 보전처분에 대한 이의신청과 보전처분의 취소신청은 별개 독립된 제도이고, 채무자로서도 신속히 보전처분의 집행력에서 해방될 필요가 있어 두 가지 신청의 경합을 긍정할 실익이 있다는 이유로 양자의 병존을 긍정하고 있다. 나아가, 이의절차와 취소절차는 심판대상이 다르기 때문에 가령 이의절차에서 취소사유가 주장되고, 그것이 인정되지 아니하였더라도 채무자는 동일한 사유를 취소절차에서 주장할 수 있다고 보는 것이 일반적이다.

실무상으로도 양자를 동시에 제기하는 경우가 많다. 위와 같이 양자가 동시에 제기된 경우에 보전취소신청을 반소와 같이 처리하면 심리상 문제점은 없으므로 양자의 병합을 허용해야 한다는 견해도 있지만, 실무는 양자의 병합을 허용하지 않고 취소신청을 취하하도록 하되 취소사유도 이의소송에서 함께 심리하거나, 처리가 용이한 사건을 먼저 처리하고 다른 사건을 사실상 정지한 다음 보전처분을 취소하는 경우에는 다른 신청을 취하하도록 권유한 다음 불응할 경우에 각하하여 재판의 모순, 저촉을 방지하는 방향으로 운용하고 있다. 143

다. 이의·취소재판 상호간의 구속력

보전재판에는 기판력이 없으므로 법원이 선행 결정을 사실상 존중하는 것은 별론으로 하더라도 선행 결정이 법적 구속력을 가지지는 않는다.

라. 취소신청과 이의신청의 상호 변경은 불허

채무자가 보전처분취소를 신청하였으나 절차가 신속하게 진행되지 않는 경우에는 보전이의신청으로 변경하여 달라고 신청하는 경우가 있다. 실무는 보전이의와 보전취소 양 절차는 현행법상 별개의 절차로 되어 있는데다 당사자의 지위가 서로 반대인 점, 보전이의 사건기록은 보전처분신청 사건기록에 합철하지만 보전취소 사건기록은 첨철하는 점 등을 고려하여 신청의 변경을 불허하고 보전이의를 새로 신청하도록 하고 있다. 보전이의신청을 보전취소신청으로 변경하는 것도 위와 같은 이유로 허용하지 않고 있다.

마. 보전처분신청이 일부인용된 경우 채권자의 즉시항고와 채무자의 보전이의신청의 경합

채권자의 보전처분신청이 일부만 인용된 경우, 채권자는 배척된 부분에 대하여 즉시항

고를, 채무자는 인용된 부분에 대하여 보전이의나 보전취소신청을 할 수 있다. 이와 같이 즉시항고사건과 이의사건이 동시에 진행되는 경우에 재판의 모순저촉 등을 우려하여 채무자의 부대항고 및 채권자의 부대이의를 허용하여야 한다는 견해도 있지만, 실무는 양 절차를 별개사건으로 처리하되 당사자의 양해를 얻어 항고사건의 절차를 사실상 정지하고 이의사건의 결과를 기다리는 방식으로 운영하고 있다.

144 5. 부당한 보전처분과 손해배상

가. 불법행위책임

(1) 보전처분이 불법행위를 구성하는 경우에는 그로 인한 손해배상의 청구도 가능하다. 다만 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임하에 하는 것이므로, 그 집행 후에 채권자가 본안소송에서 패소확정 되었다면 특별한 반증이 없는 한 채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다는 것이 판례이다(대판 1999. 4. 13. 98다52513, 대판 2010. 2. 11. 2009다82046 등). 또한 가압류신청에서 채권액보다 지나치게 과다한 금액을 주장하여 그 청구금액대로 가압류결정이 된 경우, 본안판결에서 피보전권리가 없는 것으로 확인된 범위 내에서는 가압류채권자의 고의·과실이 추정된다(대판 1999. 9. 3. 98다3757).

여기서 추정은 사실상 추정이므로 반증에 의하여 그 추정을 반복할 수 있다(대판 2010. 2. 11. 2009다82046). 어떤 경우에 추정이 깨지고 채권자에게 과실이 없다고 할 수 있는가. 일반적으로는 채무자에게 책임지울 수 있는 사정이 있어 채권자가 오인할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 부당집행에 대한 과실이 없다고 보아야 한다(대판 2011. 7. 14. 2011다13241). 채권자가 법적 해석을 잘못하여 보전처분을 한 경우에 과실을 부정한 판례도 다수 있다(대판 1980. 11. 25. 80다730, 대판 1993. 3. 23. 92다49454 참조).

(2) 부당한 가압류에 관하여 고의 또는 과실이 있는 가압류채권자는 그 가압류집행으로 손해를 입은 제3자에게도 손해를 배상할 책임이 있다(대판 2009. 2. 26. 2006다24872). 가압류채권자가 아닌 사람도 가압류채권자의 보전처분신청이 사실적·법률적 근거가 없는 권리 또는 법률관계에 기인한 것임을 알면서 또는 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고, 가압류채권자의 보전처분신청을 방조하는 행위를 하여 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 보전처분신청을 하게 만든 경

우에는 그 사람도 공동불법행위자로서의 책임을 면할 수 없다(대판 2002. 10. 11. 2002 다35461).

나. 부동산에 대한 부당한 보전처분과 손해배상

(1) 부동산에 대한 가압류·처분금지가처분의 집행과 당해 부동산의 처분지연 간에 상당인과관계가 있다고 할 수 있는가. 판례는 일정한 조건 아래 이를 긍정하고 있다. 즉 판례는 가압류의 처분금지적 효력은 상대적인 것에 불과하기 때문에, 다른 특별한 사정이 없는 한 그 가압류는 부동산을 처분함에 있어서 법률상의 장애가 될 수는 없지만, 가압류가 집행된 부동산을 매수하려는 자로서는 그 부동산의 소유권을 완전하게 취득하지 못하게 될 위험을 고려하여 당해 부동산의 매수를 꺼리게 됨으로써 결과적으로 그 부동산을 처분함에 있어 사실상의 장애가 될 수는 있으므로, 주위 부동산들의 거래상황 등에 비추어 채무자가 가압류가 집행된 부동산에 대한 처분 필요성에 기하여 처분을 계획 또는 시도하였으나 처분하지 못한 것이 당해 가압류의 집행으로 인하였을 것이라는 점이 입증되는 경우에는, 비록 가압류가 그 부동산의 처분에 있어 법률상의 장애사유가 아니라 하여도 그 가압류와 당해 부동산의 처분지연 사이에는 상당인과관계가 있다고 하였고(대판 2002. 9. 6. 2000다71715, 대판 2007. 11. 15. 2005다34919), 부동산에 처분금지가처분이 집행된 경우에도 유사한 조건 아래 이를 긍정하고 있다(대판 2001. 11. 13. 2001다26774).

(2) 그러나 부동산의 등기청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분이 부당하게 집행되어 그로 인해 부동산의 처분이 지체되었다고 하더라도, 가처분집행 당시 부동산의 소유자가 그 부동산을 사용·수익하는 경우에는 그 부동산의 환가가 지연됨으로 인한 손해는 그 부동산을 계속 사용·수익함으로 인한 이익과 상쇄되어 결과적으로 부동산의 처분이 지체됨에 따른 손해가 없다고 할 수 있고, 만일 그 부동산의 환가가 지연됨으로 인한 손해가 그 부동산을 계속 사용·수익하는 이익을 초과한다면 이는 특별손해라는 것이 판례이다(대판 2001. 1. 19. 2000다58132 등). 다만 분양할 목적으로 신축한 연립주택이 부당한 가처분으로 인하여 처분이 제한된 경우와 같이 채무자가 목적물을 사용·수익하지 않는 경우에는 처분이 지연된 기간 동안 입은 손해 중 적어도 부동산의 처분대금에 대한 법정이율에 따른 이자 상당의 금액은 통상손해에 속한다(대판 2001. 11. 13. 2001다26774).

(3) 토지에 대한 부당한 가압류집행으로 그 지상에 건물을 신축하는 내용의 공사도급계약이 해제됨으로 인한 손해는 특별손해이므로, 가압류채권자가 토지에 대한 가압류집행이 그 지상 건물 공사도급계약의 해제사유가 된다는 특별한 사정을 알았거나 알 수 있었을

때에 한하여 배상의 책임이 있다(대판 2008. 6. 26. 2006다84874).

다. 금전채권에 대한 부당한 보전처분과 손해배상

부당한 보전처분으로 인하여 그 금전채권을 제때에 변제받지 못함으로써 발생하는 통상의 손해액은 그 채권금에 대한 민법 소정의 연 5%의 비율에 의한 지연이자 상당액이고, 채무자가 실제로 부당하게 가압류된 금원을 활용하여 얻을 수 있었던 금융상의 이익이나 공탁한 돈을 조달하기 위한 금융상의 이자 상당액은 특별손해로서 채권자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 배상책임이 있다(대판 1999. 9. 3. 98다3757). 그러나 부당한 채권가압류의 집행이 있었다 하더라도 그 집행기간 동안 기한의 미도래나 조건의 불성취 등의 사유로 인해 가압류채무자가 제3채무자로부터 채권을 바로 지급받을 수 없는 사정이 있었다면 가압류채무자가 부당한 채권가압류의 집행으로 인하여 어떤 손해를 입었다고 할 수는 없다(대판 2006. 6. 15. 2006다10408).

라. 주식에 대한 부당한 보전처분과 손해배상

147 주식의 매매에서 주가가격의 상승으로 인한 이익은 주가가격의 변동성이 심하여 누구도 그 가격의 상승 여부와 그 정도를 정확하게 예측하기 어려운 측면이 있고, 주가가격이 상승하였다고 할지라도 주식소유자가 추가상승을 기대하며 주식을 매도하지 않고 계속 보유하고 있을 수도 있으며, 설사 그 당시 매도주문을 내더라도 그 주문가격에 매매가 체결되지 않는 경우도 있다. 따라서 주시가압류집행기간 동안 주가가격이 상승하였다고 하더라도 '가압류집행기간 중 주식의 최고가액과 가압류집행 당시 주식의 시가'의 차액 상당의 손해는 특별한 사정으로 인한 것이어서 ① 주식 소유자인 채무자가 가압류집행 후 주가가격이 가장 높았던 시점에 주식을 매도하여 그로 인한 이익을 확실히 취득할 수 있었고, ② 채권자가 가압류집행 당시 위와 같은 사정을 알았거나 알 수 있었던 경우에 한하여 채권자가 그 손해배상책임을 진다는 하급심 판결도 있다.

마. 동산에 대한 부당한 보전처분과 손해배상

채권자의 기계들에 대한 해체 및 반출금지가처분으로 말미암아 채무자가 그 주강공장의 기본설비인 전기주강로를 포함한 기계들을 그 설치된 장소나 또는 다른 곳에 이전하여 사용할 수 없게 됨으로써 결국 공장을 가동할 수 없게 된 경우, 부당가처분으로 인한 손해

액은 특별한 사정이 없는 한 그 공장을 가동함으로써 얻을 수 있는 이익에 상응하는 주강 공장 전체에 대한 차임 상당액을 기준으로 하여 산출하여야 하고, 이는 부당가처분과 상당 인과관계에 있는 통상의 손해이다(대판 1983. 2. 8. 80다300).

바. 해방공탁을 한 경우의 손해배상

가압류채무자가 가압류 이후 가압류청구금액을 공탁하고 그 집행취소결정을 받았다면, 가압류채무자는 적어도 가압류집행으로 인하여 공탁금에 대한 민사법정이율인 연 5% 상당의 이자와 공탁금이율 상당 이자의 차액 상당의 손해를 입었다고 보아야 한다(대판 1992. 9. 25. 92다8453, 대판 1995. 12. 12. 95다34095, 34101).

사. 위자료

148

(1) 다른 사람의 불법행위에 의하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보고, 재산적 손해의 배상에 의하여서도 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다면 이는 특별손해로서 가해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 이를 청구할 수 있다(대판 2005. 11. 10. 2005다37710 참조). 그런데 실제 사건에서 부당한 보전처분으로 인한 재산상 손해의 발생이 인정되는데도 증명곤란 등의 이유로 그 손해액의 확정이 불가능하여 배상을 받을 수 없는 경우가 많은데, 이와 같은 경우 법원이 위자료액을 산정할 때 이러한 사정을 위자료의 증액사유로 참작할 수 있다(대판 2007. 6. 1. 2005다5843, 대판 2010. 8. 26. 2009다67979 참조).

(2) 일상에 사용할 성질의 가재도구를 장기간 가압류당한 채무자에게 정신상의 고통이 있었음은 경험칙상 인정할 수 있고(대판 1967. 9. 19. 67다1219), 부당한 가처분집행으로 채무자가 공장을 운영하지 못하고 제품과 기구의 점유마저 방해당하여 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의 손상 등을 초래케 되어 정신상 고통을 적지 않게 받았으리라는 것은 경험칙에 의하여 이를 인정할 수 있다(대판 1972. 1. 31. 71다2368). 채권자의 채무자에 대한 가처분사건으로 인하여 채무자가 7년이라는 긴 세월 동안에 계획했던 제품의 제조와 판매를 금지 당하였고 또 가처분에 대한 이의소송, 본안에 대한 응소, 그 본안사건의 전제가 된 특허권쟁송 등으로 인하여 적지 않은 재산상 손해를 입었고, 채무자의 명예·신용 및 사회적 목적 사업수행에도 많은 영향을 받은 것이 인정되는 경우 채무자에 대한 위자료를 인용함이 상당하다(대판 1980. 2. 26. 79다2138, 2139)고 판시한 사례가 있다.

아. 소송비용

부당한 가처분의 취소를 위하여 변호사에게 사건처리를 위탁한 사람은 자신이 지급한 변호사보수 전액이 아니라 소송비용액확정절차를 거쳐 상환받을 수 있는 부분을 제외한 나머지 금액만을 손해배상 청구할 수 있다(대판 2000. 12. 22. 2000다54390).

자. 과실상계

부당한 보전처분으로 인한 손해배상책임을 민법상의 불법행위책임으로 보는 이상 이에 대하여도 민법 763조, 396조에 따라 과실상계가 인정된다. 사용금지가처분의 집행을 받은 채무자가 제3자이의의 소를 제기하여 제1심에서 그 가처분집행을 불허하는 취지의 승소판결과 가집행의 선언이 있었음에도 불구하고 집행정지나 가처분에 대한 해제조치를 취하지 않음으로써 손해가 증대되었다면 과실상계를 해야 하고(대판 1970. 11. 30. 70다2218), 채무자가 집행관의 위탁으로 보관하는 그 소유의 철망을 오랫동안 그가 지배하는 창고 내에 보관함으로 인하여 녹이 슬게 될 것을 예견하면서도 이를 방지하기 위한 적당한 처분을 할 것을 집행관에게 촉구하지 아니한 경우 과실을 참작하여야 한다(대판 1975. 2. 25. 74다1590). 채무자가 쌀이 부패하기 쉬운 물건임을 알면서 위 쌀의 보관방법에 관한 필요한 조치를 집행관에게 촉구하거나 또는 법원에 대하여 환가처분에 의한 금전보관방법 등 적절한 조치를 강구하지 않았다면 채무자에게도 과실이 있다(대판 1972. 5. 23. 72다439).

6. 가처분의 취소와 원상회복

가. 의의

가처분을 명한 재판에 기초하여 채권자가 물건을 인도받거나, 금전을 지급받거나 또는 물건을 사용 보관하고 있는 경우에는, 법원은 가처분을 취소하는 재판에서 채무자의 신청에 따라 그 취소의 재판과 동시에 그 물건이나 금전을 반환하도록 명할 수 있다(민집 308조).

150 나. 성격

원상회복재판은 가정성·잠정성에 기초한 가처분에 관하여 행해지는 것이어서 기판력이 없고 권리의 존부를 확정시키는 것도 아니므로, 가집행선고의 취소에 따른 가지급물 반환

의 경우와는 달리 원상회복의 범위는 채권자에게 인도되었던 물건이나 금전에 국한되고, 별도로 손해배상의무의 존부에 관하여 판단할 수는 없다.

원상회복재판은 가처분을 취소하는 재판과 함께하게 되는데, 이 경우 가처분을 취소하는 재판의 원인은 가처분에 대한 이의신청이든 취소신청이든 관계없다. 원상회복재판신청은 가처분이의·취소신청에 부수하는 신청이다. 반드시 가처분이의·취소신청과 동시에 할 필요는 없으므로 심리종결에 이를 때까지 추가적으로 신청할 수 있다. 채무자가 가처분이의·취소절차에서 원상회복재판을 신청하지 아니한 경우에는 항고의 단계에서도 원상회복재판을 신청할 수 있다. 채무자가 가처분이의·취소절차에서 원상회복재판을 신청하였으나 가처분이의·취소신청이 기각되어 보전항고를 제기한 경우에는 명시적으로 신청한 경우가 아니더라도 원상회복재판신청을 유지하고 있는 것으로 해석하여야 한다. 가처분이의·취소신청을 취하하는 경우에는 원상회복재판신청도 실효되고, 채권자가 가처분신청을 취하하는 경우에도 가처분이의·취소신청은 실효되어 원상회복의 재판신청도 아울러 실효된다.

다. 심리와 재판

(1) 원상회복재판은 부수적인 재판이므로, 가처분이의·취소·보전항고의 심리와 일체로 진행한다. 가처분은 보전의 필요성이 소멸하였음을 이유로 취소할 수도 있는 등 가처분을 취소할 사유가 있다고 하여 반드시 채무자가 본안소송에서 승소한다고 단정할 수 없으므로, 법원은 구체적 사안에 따라 원상회복재판의 필요성을 재량으로 판단할 수 있다. 따라서 법원은 가처분은 전부 취소하면서 원상회복재판신청은 그 전부 또는 일부를 기각할 수도 있다. 채권자의 생계를 위하여 임시로 임금이나 치료비의 정기지급을 명하였으나 후에 더 이상 임시로 금원을 지급하도록 할 필요가 없을 경우 가처분을 취소하면서 이미 지급한 금원의 원상회복은 명하지 않는 경우 등이 대표적인 예이다. 151

(2) 원상회복재판신청에 대하여 채권자가 본안에서 심리된 청구권(피보전권리)을 자동채권으로 하여 상계한다는 주장을 하는 것은 채무자에게 간이·신속한 구제수단을 마련한 제도의 취지에 어긋나므로 허용되지 않는다.

(3) 원상회복재판은 가처분이의·취소·보전항고재판에 부수하는 것으로서 민사집행법 56조 1호 소정의 '항고로만 불복할 수 있는 재판'에 해당하고, 가집행선고나 집행문을 부여받을 필요 없이 즉시 집행력을 가지며, 집행기간도 2주 이내로 제한되지 않는다.

(4) 원상회복재판은 가처분취소재판에 부수된 재판의 형식으로 이루어지는 것이므로 원상회복재판에 대해서만 별도로 불복할 수 없고, 이에 불복하는 경우에는 가처분이의·취

소·보전항고 재판에 대한 불복절차에 의하여야 한다. 같은 법리로 가처분취소재판에 대한 불복을 이유로 집행정지가 된 경우, 그 집행정지의 효력은 원상회복명령에도 미친다.

7. 가처분에 대한 불복과 집행정지 및 집행취소

가. 의의

보전처분은 당연히 집행력이 있고, 채무자의 이의가 제기되었다고 하여 보전처분의 집행력이 당연히 정지되지는 않는다(민집 283조 3항, 301조, 49조).

민사집행법은 보전소송제도의 취지를 살리면서도 이로 인하여 채무자에 대하여 부당하게 회복할 수 없는 손해를 입히는 일이 있어서는 안 된다는 원칙에서, 소송물인 권리 또는 법률관계가 이행되는 것과 같은 내용의 가처분을 명한 재판에 대하여 이의신청이 있는 경우에, 이의신청으로 주장한 사유가 법률상 정당한 이유가 있다고 인정되고 주장사실에 대한 소명이 있으며, 그 집행에 의하여 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 사정에 대한 소명이 있는 때에는, 법원은 당사자의 신청에 따라 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하지 아니하고 가처분의 집행을 정지하도록 명할 수 있고, 담보를 제공하게 하고 집행한 처분을 취소하도록 명할 수 있도록 하였다(민집 309조 1항).

나. 요건

(1) 민사집행법은 집행정지의 요건으로서 소송물인 권리 또는 법률관계가 이행되는 것과 같은 중국적인 만족을 얻게 하는 내용의 가처분인 점과 가처분의 집행에 의하여 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있는 점을 병렬적으로 요구하고 있다.

집행정지는 어떤 종류의 가처분에 대하여 가능한가. 입법취지를 보면 집행정지는 만족적 가처분 중 부동산철거단행가처분(대결 1995. 3. 6. 95그2), 점포인도단행가처분(대결 1996. 4. 24. 96그5), 회계장부의 열람·등사가처분(대결 1997. 3. 19. 97그7), 임금지급가처분과 같이 이행소송을 본안으로 하는 이행적 가처분에 한하여 허용되고, 경압금지가처분, 통행방해금지가처분, 이사직무정지가처분 등 형성적 가처분에서는 집행정지를 허용하지 않는 것으로 보는 견해가 실무상 다수의 견해이다.

예를 들면 특허권등침해금지가처분의 내용이 특허권 등의 침해를 예방하기 위하여 채무자로 하여금 정화조와 성형장치 등의 처분을 금지하고 집행관에게 보관시키는 것에 불과하며, 소송물인 권리 또는 법률관계의 내용이 이행된 것과 같은 중국적 만족을 얻게 하는

것이 아닌 경우에는 그 가처분결정에 대한 집행정지는 허용되지 않는다(대결 2002. 5. 8. 2002그31).

부작위를 명하는 가처분의 집행정지도 가능한가. 공사금지가처분 등 부작위를 명하는 가처분에 대하여는 그 본안소송이 이행소송이고, 본안소송으로 피고에게 명하는 부작위의 무나 가처분으로 명하는 채무자의 부작위의무에 아무런 차이가 없음을 이유로 집행정지가 가능하다는 주장도 있다. 그러나 민사집행법의 집행정지는 이행적 가처분, 즉 이행소송을 본안으로 하는 단행가처분에만 허용됨을 명시하고 있으므로, 이 문제는 부작위를 명하는 가처분이 권리보전의 범위에 그치는 가처분에 해당한다고 보느냐 그렇지 않으면 권리보전의 범위에 그치지 아니하고 소송물인 권리 또는 법률관계가 이행되는 것과 같은 종국적 만족을 얻게 하는 내용의 가처분에 해당한다고 보느냐에 따라 결정될 것이다. 다만 부작위를 명하는 가처분의 경우에는 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이라는 요건을 갖추기가 어려워 이에 대하여 집행정지를 인정하는 경우는 드물다.

(2) 담보제공 여부에 관하여는, 집행정지와 집행취소를 구별하여 집행정지 시에는 담보제공이 임의적이나 집행취소를 위해서는 담보제공이 필수적이다(민집 309조 1항). 담보제공명령을 먼저 발령하고 담보가 제공되면 집행정지결정을 할 수도 있고, 담보제공을 조건으로 집행정지를 명할 수 있다.

(3) 가처분의 집행으로 인하여 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 점에 대한 소명과, 이의사유로 주장한 사실에 대한 소명에 관하여는 보증금의 공탁이나 선서로 대신할 수 없다(민집 309조 2항). 집행정지 제도의 엄격한 운용을 담보하기 위한 것이다.

다. 관할법원

집행정지의 재판은 재판기록이 원심법원에 있는 때에는 원심법원이 관할법원이 된다(민집 309조 3항). 1심법원에서 가처분신청을 기각하고 항고법원에서 가처분명령을 발령한 경우에는 가처분이의의 관할법원은 항고심이므로 집행정지 및 취소의 재판은 항고법원이 담당한다.

라. 재판의 내용

법원은 가처분이의신청에 대한 결정에서 기왕의 집행정지 또는 집행취소결정을 인가·변경 또는 취소하여야 한다(민집 309조 4항).

집행정지재판은 부수적인 재판이므로 독립하여 불복하지 못한다. 집행정지재판을 인가·변경 또는 취소하는 재판에 대하여도 불복할 수 없다(민집 309조 5항).

154 마. 가처분취소에의 준용

가처분취소신청도 그 목적이 가처분취소를 구하는 점에서는 가처분이의와 동일하고, 집행정지에 관하여 양자를 달리 취급할 필요가 없으므로, 가처분취소에도 가처분이이의 집행정지 및 취소에 관한 규정이 준용된다(민집 310조).

제2절 보전처분에 대한 이의

1. 이의절차의 구조

(1) 이의는 채무자가 보전처분을 발령한 법원에 대하여 그 보전처분의 취소나 변경을 구하는 불복제도이다. 보전처분신청을 배척하는 결정(각하·기각)에 대하여는 즉시항고의 방식에 의하여 불복하는 것과(민집 281조 2항, 301조) 구별된다.

(2) 이의절차에서 심리의 대상이 되는 것이 보전처분신청의 당부인가 보전처분의 당부인가에 관하여 논의가 있으나, 보전처분에 대한 이의는 지급명령에 대한 이의와 같이 같은 심급에서의 불복신청으로서 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문 또는 임의적 변론을 거쳐 다시 보전처분신청의 당부를 심리·판단하여 달라는 신청으로 보는 것이 통설 및 실무레이다(대판 1965. 7. 20. 65다902). 따라서 판단의 기준시도 보전처분 시가 아닌 이의소송의 심리종결 시이다(대판 1978. 2. 14. 77다938 참조). 그리고 보전처분신청의 소송대리인은 보전처분에 대한 이의소송에서도 여전히 소송대리인의 지위를 유지한다.

(3) 지급명령에 대한 이의신청과 다른 점은 이의가 있다 하여 곧 보전처분의 효력이 실효되지 않는다는 점이다. 따라서 이의절차의 결정에는 보전처분신청의 당부 외에 이미 발령된 보전처분의 취소·변경·인가를 선언하여야 한다.

155 (4) 이의소송의 구조는 민사집행법의 개정으로 인하여 동일한 심급 안에서 복심에서 속심으로 바뀌었으므로, 보전처분신청에 대한 심리단계에서 이미 제출된 자료는 당연히 모두 이의소송의 소송자료가 되고 절차를 다시 진행할 필요가 없다.

2. 관할법원과 이송

(1) 이의사건은 보전처분을 발령한 법원의 전속관할에 속한다. 따라서 본안에 관한 항소

심법원이 보전처분을 하였을 때에는 이의사건도 그 항소심법원의 관할에 전속한다. 채권자의 보전처분신청이 제1심에서 배척되고 채권자의 항고에 의하여 항고심에서 보전처분을 하게 된 경우 이의사건의 관할법원이 어디인가에 관하여는 논의가 있는데, 통설이나 판례는 항고심법원이 관할법원이라고 한다(대결 1991. 3. 29. 90마819, 대결 1999. 4. 20. 99마865). 보전처분을 신청한 법원에 이의신청을 하여야 한다면 상급심이 한 재판의 당부를 하급심이 판단하는 것이 되어 심급제도의 취지에 어긋날 뿐만 아니라 이의사건은 보전처분신청에 대한 심리의 속행적 성격을 가지므로 심리한 항고법원에 이의를 신청함이 타당하다. 합의부가 발령한 보전처분에 대한 이의사건을 단독판사가 심리·재판하는 것은 전속관할에 위반된다.

(2) 민사집행법은 이의사건을 담당하는 법원이 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위한 필요가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 결정으로 그 가압류·가처분사건의 관할권이 있는 다른 법원에 사건을 이송할 수 있도록 하였다. 다만 이송받는 법원이 심급을 달리하는 경우에는 이송하지 못한다(민집 284조). 심급을 달리하는 경우에 이송을 허용하지 않는 이유는, 이를 허용하면 절차상으로 여러 가지 복잡한 문제가 생기기 때문이다.

(3) 이의사건이 이송되면 원래의 보전소송사건도 이송받은 법원으로 함께 이송된다. 따라서 보전처분의 집행해제 등 사후의 절차는 모두 이송받은 법원에서 담당하게 된다.

(4) 앞서 본 문제점은 가압류취소소송과 가처분취소소송에서도 동일한 것이므로, 보전처분의이의소송의 이송에 관한 규정은 보전처분취소소송에도 준용된다(민집 290조 1항, 301조, 307조 2항). 156

3. 신청과 접수

가. 이의신청인

(1) 채무자, 일반승계인, 파산관재인

(가) 고유의 이의신청권자

민사집행법상 누가 이의신청권자인지에 관한 명문의 규정은 없다. 그러나 보전이의는 보전처분에 의하여 직접 권리의 제한·침해를 받는 채무자에게 인정된 특유한 불복 방법으로서, 이미 개시된 가압류·가처분의 소송절차에서 그 소송을 수행하기 위한 절차상의 권리에 지나지 않는 것이므로, 원칙적으로 그 소송절차의 주체인 소송당사자(보전처분결정에 채무자로 표시되어 있는 자)와 그 일반승계인, 파산관재인이 이의신청권자가 된다(대결

2011. 9. 21. 2011마1258).

(나) 채무자가 사망한 경우

채권자의 보전신청 당시 채무자가 생존하고 있었던 이상 그 결정 직전에 채무자가 사망하여 사망한 자를 채무자로 하여 보전처분이 발령되었더라도 이를 당연 무효라고 할 수 없으므로(대판 1993. 7. 27. 92다48017), 채무자의 상속인이 이의신청을 할 수 있다.

보전신청 이전에 이미 사망한 자를 채무자로 한 보전신청의 경우에도 그러한 신청은 부적법하고 그 신청에 따른 보전처분이 있었다고 하여도 그 결정은 당연 무효로서 그 효력이 상속인에게 미치지 않기는 하지만, 채무자의 상속인들은 일반승계인으로서 무효인 그 보전처분에 의하여 생긴 외관을 제거하기 위하여 보전의이의신청으로써 그 취소를 구할 수 있다(대판 2002. 4. 26. 2000다30578). 한편 무효인 보전처분에 기한 집행에 대하여 상속인들은 제3자이의의 소를 제기할 수 있고 그 승소확정된 판결정본을 첨부하여 집행법원
157 에 집행취소를 구할 수 있다(대판 1982. 10. 26. 82다카884).

채무자의 상속인들이 이의신청을 하여야 하는 경우 상속인 전원이 이의신청을 하여 보전처분 전부의 취소를 구할 경우에는 아무런 문제가 없으나 상속인 중 일부만이 보존행위로서 자신의 지분을 초과한 부분에 대하여도 이의할 수 있는가의 문제가 있다. 보전처분의 의소송의 성질은 보전처분신청의 당부를 판단하는 것이지, 채권자가 보전처분신청을 통하여 실시한 가압류나 가처분 등기의 말소를 구하는 것이 아니므로, 보전처분의의소송에서는 채무자의 상속인 중 1인이 자신의 상속분을 넘어서는 다른 상속인의 상속지분에 관하여 다투는 것은 허용되지 않는다 할 것이다. 반면, 채무자의 상속인이 제3자이의의 소를 제기하여 이미 실시한 가압류나 가처분 등기의 말소를 구한다면 이는 방해배제로서 보전처분의 말소를 구하는 것이므로 공유자 중의 1인이라 하더라도 보전행위로서 자신의 지분을 초과한 부분에 대하여도 권리행사가 가능하다.

(2) 특정승계인(부정)

민사집행법 283조에 의하여 가압류결정에 대한 이의신청을 할 수 있는 자는 채무자와 그 일반승계인이라야만 하고, 특정승계인은 직접 자기 이름으로 이의신청을 할 수 없으며 민사소송법 81조에 의한 참가승계를 하는 경우에만 이의신청을 할 수 있을 뿐이다(대판 1970. 4. 28. 69다2108). 그 이외의 제3자는 가압류에 대하여 사실상의 이해관계가 있다 하더라도 이의를 신청할 적격이 없다. 나아가 의무승계를 이유로 하는 참가에 있어서 그 참가신청의 이유로서 주장하는 사실관계 자체에서 승계적격의 흠결이 명백한 경우에는 그

승계참가신청은 부적법하다(대결 2017. 2. 17. 2016마993).

(3) 제3채무자(부정)

채권가압류명령 중에 제3채무자에게 지급금지를 명하는 내용이 있기는 하나 이는 가압류명령 자체의 내용이 아니고, 제3채무자는 가압류명령의 직접 당사자가 아니며, 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 부존재하는 경우 가압류결정은 제3채무자에 대하여 실제법상 아무런 효력이 없으므로 제3채무자는 가압류결정에 대한 이의신청을 할 수 없다(대판 1967. 5. 2. 67다267).

가압류의 목적물이 처음부터 제3자에게 속하거나 가압류집행이 반사회적인 행위로 이루어져 무효이므로 가압류 후 가압류목적물의 소유권을 취득한 제3자가 가압류의 효력을 부정할 수 있는 경우(대판 1996. 6. 14. 96다14494 참조), 근저당권이 있는 채권이나 전세권이 있는 채권을 가압류한 경우 목적부동산의 소유자인 동시에 설정자인 제3채무자가 가압류된 채권의 변제나 부존재 등을 이유로 각 제3자이의의 소로써 가압류집행의 배제를 구할 수는 있으나 제3자 명의로 직접 가압류이의신청을 할 수는 없다.

하지만 가처분의 피보전권리의 전부 또는 일부가 가처분결정 당시부터 자기의 권리라고 주장하는 제3자가 동시에 자기의 권리보전의 필요가 있다고 할 때에는 민사소송법 79조에 의한 독립당사자참가를 할 수 있고 따라서 그 제3자는 참가신청과 동시에 당해 가처분결정에 대하여 이의신청을 할 수 있다.

(4) 채무자의 채권자(부정)

보전처분에 대한 이의신청은 보전처분에 대한 소송법상의 불복방법에 불과하고, 채권자대위권에 의하여 소송절차상 개개의 권리를 행사하는 것은 허용되지 아니하므로, 채무자의 채권자가 채권자의 대위에 의하여 이의신청을 할 수 없다(대판 1967. 5. 2. 67다267).

하지만 이의절차와는 달리 사정변경 또는 특별사정에 의한 취소신청은 이미 개시된 보전소송절차와는 별개의 독립된 신청이므로 대위에 의한 취소신청도 가능하다.

(5) 공동수급체의 경우 가압류 상대방 및 이의신청인

민법상 조합에서 조합의 채권자가 조합재산에 대하여 강제집행을 하려면 조합원 전원에 대한 집행권원을 필요로 하고, 조합재산에 대한 강제집행의 보전을 위한 가압류의 경우에도 마찬가지로 조합원 전원에 대한 가압류명령이 있어야 할 것이므로, 조합원 중 1인만을 가압류채무자로 한 가압류명령으로써 조합재산에 가압류집행을 할 수는 없다(대판 2015.

- 159 10. 29. 2012다21560). 그럼에도 조합원 중 1인만을 채무자로 하여 그 공동수급체의 합유재산인 공사대금채권을 가압류한 경우, 다른 공동수급체 구성원은 제3자이의의 소로써 가압류집행의 배제를 구할 수 있다(대판 1997. 8. 26. 97다4401).

반대로 공동수급체 구성원 중 1인에 불과할 뿐 업무집행사원이 아닌 업체가 채권자로서 도급자를 채무자로 하여 공동수급체의 공사대금채권을 근거로 가압류 신청을 한 사안의 경우에, 실무는 채무자에 대한 공사대금 청구권은 채권자 등으로 구성된 공동수급체의 합유재산이므로 채무자를 상대로 하여 그 이행을 청구하는 소는 조합원인 공동수급체 구성원 전원이 공동으로만 제기할 수 있는 고유필수적 공동소송이라 할 것인데, 채권자는 그 구성원 중 1인에 불과할 뿐만 아니라 업무집행자도 아니므로, 채권자가 단독으로 채무자를 상대로 하여 공사대금청구권을 피보전권리로 하여 구하는 가압류신청은 신청인적격이 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법하다는 이유로 가압류신청을 각하하고 있다.

채권자에 대한 채무를 부담하는 공동수급체 구성원인 채무자 본인이 공사대금채권이 합유라는 점을 근거로 가압류이의를 신청할 수 있는가에 관하여 이를 긍정하는 견해도 있지만, 다수 실무례는 피가압류채권이 채무자 개인의 채권이 아니라 공동수급체의 채권으로서 조합의 합유재산으로 인정된다고 할지라도 채권가압류에 있어 채무자가 제3채무자에 대한 채권이 없다면 가압류 채무자는 채권자의 가압류 결정에 의하여 법률상 아무런 불이익을 받을 지위에 있다 할 수 없으므로 가압류에 대한 이의를 신청할 이익이 없다거나(대판 1967. 5. 2. 67다267), 그와 같은 사유는 보전처분의 효력과 관련된 것이 아니라 보전처분의 집행과 관련된 하자이므로 제3자 이의의 소나 집행에 관한 이의로써 다투면 족할 뿐 가압류 이의사유로서 다룰 것은 아니라는 이유로 이의신청을 각하하거나, 가압류신청을 인가하면서 이의신청을 기각하고 있다(서울고결 2012. 1. 31. 2011라1358).

(6) 직무집행이 정지된 이사

- 160 직무집행정지가처분을 받은 이사는 직무집행정지가처분을 받은 당해 사건에 관하여는 가처분의 당부를 다룰 수 있기 때문에 당연히 이의신청을 할 수 있다. 한편 직무집행정지가처분 사건에서 회사는 채무자 적격이 없다(대판 1997. 10. 10. 97다27404).

나. 상대방

보전이의의 상대방은 당해 보전처분의 채권자, 그 일반승계인, 파산관재인이 된다. 피보전권리가 제3자에게 양도되었더라도 채권자는 여전히 상대방적격을 갖는다(대판 1993.

7. 13. 92다33251). 채권자의 특정승계인이 보전이의의 심리에 승계참가하는 경우 보전처분에 관한 승계집행문을 부여받을 필요는 없다는 견해도 있지만, 절차적 안정성을 위하여 이 경우에도 승계집행문을 부여받는 것이 바람직하다고 보는 것이 타당하다.

4. 이의신청의 시기와 이의의 이익

가. 원칙

이의신청의 시기에 관하여는 법률상 제한이 없으므로 보전처분이 유효하게 존재하고 취소·변경을 구할 이익이 있는 한 언제든지 할 수 있다. 취소·변경을 구할 이익은 보전처분이 갖는 효력의 제거에 대한 이익을 말하므로 보전처분이 집행되었는지 여부에 관계없다. 즉 가압류나 가처분집행의 유무, 집행기간의 경과, 본안소송의 계속 여부 및 그 본안소송에서 피보전권리의 부존재를 이유로 채권자패소로 확정된 사정 등은 보전처분의 효력에 영향을 주지 않으므로 이의신청의 장애사유가 되지 않는다. 본안판결에서 채권자 승소의 확정판결이 있는 후에도 본안판결에 기한 강제집행의 착수가 있기까지는 아직 집행보전이라는 보전처분의 목적은 달성되었다고 할 수 없기 때문에 이의신청의 이익이 있다.

나. 이의신청의 이익이 없는 경우

161

(1) 보전집행이 본집행으로 이전된 경우

가압류가 본압류로 이전되어 강제집행이 이루어진 경우에는 가압류집행은 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있게 되므로, 본집행이 되어 있는 한 채무자는 가압류에 대한 이의신청이나 취소신청 또는 가압류집행 자체의 취소 등을 구할 실익이 없게 되므로(대결 2013. 10. 23. 2013마1523), 이의신청을 부적법하다고 각하하여야 한다(대판 2002. 4. 26. 2000다30578).

(2) 금지기간이 경과한 경우

영업비밀의 침해와 전직을 금지하는 가처분에서 금지기간을 정한 경우에 그 금지기간의 경과로 가처분의 효력이 상실되었다면, 채무자는 더 이상 이의신청으로 가처분의 취소나 변경을 구할 이익이 없다(대판 2004. 10. 28. 2004다31593). 그러나 가처분결정과 함께 그 의무 위반에 대한 간접강제결정이 내려진 경우에는 채무자는 위 금지기간 경과 후에도 금지기간 중의 의무위반을 이유로 간접강제결정에 기하여 집행당할 위험이 존재하므로 그

배제를 위하여 이의신청으로 가처분의 취소를 구할 이익이 있고, 또 위 이의신청에 따른 재판에 대하여 항고할 이익도 있다(대결 2007. 6. 14. 2006마910).

가처분에 의해 직무집행이 정지된 당해 이사 등을 선임한 주주총회 결의의 취소나 그 무효 또는 부존재확인을 구하는 본안소송에서 가처분채권자가 승소하여 그 판결이 확정된 경우 가처분은 그 직무집행정지기간의 정함이 없는 경우에도 본안승소판결의 확정과 동시에 그 목적을 달성한 것이 되어 당연히 효력을 상실하게 되므로(대판 1989. 9. 12. 87다카2691), 채무자는 더 이상 이의신청으로 가처분의 취소나 변경을 구할 이익이 없다.

(3) 파산이 선고된 경우

- 162 파산선고 전에 파산채권에 관하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 한 보전처분은 파산재단에 대하여는 그 효력을 상실하므로, 파산관재인은 집행기관에 대하여 파산선고결정 등본을 취소원인서면으로 소명하여 보전집행취소신청을 하여 집행의 외관을 없앨 수 있고, 따라서 보전처분에 대한 채무자의 이의신청은 그 이익이 없어 부적법하다(대판 2002. 7. 12. 2000다2351).

(4) 보전신청이 취하된 경우

채권자는 보전처분이 발령된 이후라도 상대방의 동의를 받을 필요 없이 보전처분신청을 취하할 수 있고, 보전처분신청이 취하되면 소 취하에 준하여 보전처분신청사건은 처음부터 계속되지 아니한 것으로 보게 되므로(민소 267조 1항, 민집 23조 1항) 보전처분신청이 취하된 후에는 채무자는 이의를 신청할 수 없다. 이 경우 이미 발령된 보전처분결정은 당연히 효력을 상실하고, 채무자는 신청취하증명원을 집행기관에 제출하여 집행취소를 받을 수 있다.

다. 단행가처분집행 후라도 이의신청 가능

단행가처분이 집행되어 본안판결에 의하여 집행한 것과 동일한 결과가 생긴 경우라도 그것은 어디까지나 임시적인 것에 지나지 않고, 본안소송의 심리에서는 그와 같은 임시적, 잠정적 이행상태를 고려함이 없이 그 목적물의 점유는 여전히 채무자에게 있는 것으로 보아야 하고(대판 2007. 10. 25. 2007다29515), 집행력 있는 판결정보 등 집행권원에 기하여 본집행으로 이행되기까지 가처분의 효력은 존속되므로, 채무자로서는 보전처분이 유효하게 존속하는 동안 이의를 신청할 이익이 있다(서울고결 2015. 10. 6. 2015카합79).

그러나 부동산인도단행가처분이 집행된 후 가처분 대상 목적물이 확정적으로 멸실되는 등 전체적인 강제집행이 실질적으로 종료된 것과 같이 평가할 수 있는 사정이 있는 경우라

면 그 가치분결정의 집행력은 이미 소멸되었다고 보아야 할 것이므로, 그 경우에는 채무자가 집행력을 상실한 가치분결정에 대하여 더 이상 이의신청으로 취소나 변경을 구할 이익이 없다(서울고결 2017. 11. 27. 2017카합29).

5. 이의신청의 방식과 이의사유

163

제3편
제5장
제2절

가. 이의신청의 방식

(1) 이의신청은 신청의 취지와 이유 및 사실상의 주장을 소명하기 위한 증거 방법을 적은 서면으로 하여야 한다(민집규 203조). 신청이유에는 보전처분의 취소나 변경을 신청하는 이유를 밝혀야 한다(민집 283조 2항, 301조). 그러나 이의신청서는 소장의 구실을 하는 서면이 아니고 일종의 답변서와 같은 구실을 하는 것이므로, 이 규정은 심리의 준비를 명하는 훈시적 규정에 불과하여 구체적인 취소·변경사유(이의사유)가 기재되어 있지 아니하여도 그 신청이 부적법한 것은 아니다.

(2) 통상 이의신청취지로는 “위 당사자 사이의 ○○법원 20○○카단○○ 부동산가압류 신청사건에 관하여 20 . . . 이 법원에서 한 가압류결정을 취소한다. 채권자의 가압류 신청을 기각한다.”라는 식으로 기재하고, 신청이유로서 그 보전처분신청이 부당하다는 방어방법에 관한 주장과 항변을 기재함이 보통이다.

나. 인지의 첨부

가압류이의·다툼의 대상에 관한 가치분이의신청서에는 각 10,000원의 인지를 붙여야 하고, 임시의 지위를 정하기 위한 가치분이의신청서에는 본안의 소에 따른 인지액의 2분의 1에 해당하는 인지를 붙여야 한다(인지 9조 2항, 다만 상한은 50만 원이다).

다. 이의사유

(1) 원칙적으로 아무런 제한이 없음

보전처분신청의 당부를 심리하는 것이므로 채권자가 적극적 당사자로서 보전처분의 인가를 구하여야 되고 채무자는 소극적 당사자로서 신청의 기각과 이미 발령한 보전처분의 취소, 변경을 구함으로써 족하다. 따라서 원고에 대응하는 것은 채권자이고 피고에 대응하는 것은 채무자이며, 소장에 대응하는 것은 보전처분신청서이고 답변서에 대응하는 것은

164

이의신청서가 된다(대판 1965. 7. 20. 65다902).

이의사유에 관하여는 아무런 제한이 없다. 이는 사정변경, 특별사정, 소제기간경과 등에 의한 보전처분의 취소에서 그 사유가 제한되어 있는 것과 다르다. 따라서 채무자는 피보전권리 및 보전의 필요성의 존부에 관한 사유는 물론이고 그 외에도 이미 발령된 보전처분을 부당하게 하는 모든 사유를 이의사유로 주장할 수 있다.

(2) 보전처분 취소사유도 이의사유로 주장가능

사정변경에 해당하는 사유(대판 1981. 9. 22. 81다638), 특별사정의 존재 및 제소기간의 경과(대판 2000. 2. 11. 99다50064)도 이의사유로서 주장할 수 있는데, 이와 같은 사유는 그에 기한 취소절차가 별도로 마련되어 있지만 소송경제, 심리의 중복방지라는 실제상의 고려와 함께 이와 같은 사유도 결국은 이미 발령된 보전처분을 부당하게 하는 점에서 그 밖의 이의사유와 달리 볼 필요가 없기 때문이다.

(3) 절차적, 실체적 사유 모두 주장 가능

채무자는 당사자능력·소송능력·소송대리권 등의 흠이나 관할위반 등 절차상의 위법사유 뿐만 아니라 피보전권리·보전의 필요성의 부존재·소멸 등 실체적 요건에 관한 사유도 이의사유로 주장할 수 있다.

(4) 이의사유가 여러 개인 경우

채무자의 이의사유가 여럿이라면 이를 한꺼번에 주장하여야 하고 이의사유별로 이의신청을 하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이의사건이 계속 중에 별개의 이의사유를 주장하여 새로운 이의를 신청하는 것은 부적법하므로 각하하여야 한다. 하지만 채무자는 이의신청서에 명시하지 아니한 사유도 심리과정에서 추가로 주장할 수 있으므로 별개로 이의신청을 내지 않고 진행 중인 이의신청 사건에서 별개의 이의사유를 추가로 주장하는 것은 아무런 문제가 없다.

(5) 보전처분 발령 후 사정도 이의사유가 됨

이의사유가 되는 것은 보전처분 발령 당시의 사정에 국한되지 아니하고 이의사건의 심리종결 시까지의 사정이 모두 이의사유가 된다.

(6) 담보액

담보액이 상당하지 아니하다는 사유에 관하여는 그 액수가 법원의 재량에 의하여 정하

여진다는 이유로 이의사유가 될 수 없다는 부정설과 그 제공을 조건으로 보전처분이 발령되었다면 그것은 보전처분의 내용을 이룬다고 보아 이의사유로 삼을 수 있다는 긍정설이 있다. 긍정설이 타당하다고 본다. 실무상으로는 담보액이 상당하지 않다고 채권자가 다투는 경우에(특히 형편이 어려운 다수의 소액임차인 등이 현금담보의 제공을 요하는 예금채권 가압류 등을 신청하여 일부 금액에 대하여 현금담보 제공명령이 발령된 후 현금담보액의 감축이나, 전액 지급보증위탁계약을 맺은 문서에 의한 담보제공 허가를 해달라고 요청하는 경우), 이의신청 대신에 담보액의 감축이나 지급보증위탁계약을 맺은 문서에 의한 담보제공의 허가를 요청하는 담보변경 신청서를 제출하는 경우가 많은데, 이러한 경우에 다수 법원에서는 법원이 신청서에 첨부된 채권자의 재산상황 등에 대한 소명 자료를 심사한 후 신청이 이유가 있다고 판단되면 재도의 고안의 형식으로 종래의 담보제공명령을 취소하고 새로이 현금 담보액을 감축하거나 전액 지급보증위탁계약을 맺은 문서에 의한 담보를 제공하도록 하는 내용을 담은 담보제공명령을 발령하여 주고 있다.

(7) 집행기간의 도과

보전처분의 집행기간이 경과하였다는 사유도 이의사유가 된다. 집행기간이 경과하면 채권자는 집행에 착수할 수 없고, 집행이 허용되지 않는 보전처분신청은 신청의 이익이 없기 때문이다.

(8) 집행취소 신청한 경우

166

채권자가 보전집행취소를 신청한 경우에도 이의사유가 인정되는지 여부가 문제된다. 통상 보전집행취소신청에 보전처분신청취하의 의사가 포함된 것으로 보아 보전처분신청취하를 이유로 사건을 종국처리하면 되지만, 예외적으로 보전집행취소의사만 있다는 것이 명백한 경우에는 이의사유가 인정되는 것으로 보아 보전처분을 취소하여야 할 것이다.

(9) 가압류금지 등

신탁법 22조 1항에 위반하여 발령된 부동산가압류, 주택법 61조 3항에 따른 금지사항의 부기등기가 마쳐진 주택전설대지에 대한 가압류나 가처분(대판 2004. 11. 26. 2004다 46649), 민사집행법 246조나 각종 특별법상의 압류금지조항에 위반하여 발령된 채권가압류와 같이 당해 목적물에 대한 가압류가 허용되지 아니하는 경우에도 실무는 대체로 채무자가 보전처분에 대한 이의를 할 수 있는 것으로 보고 있다.

(10) 적법한 이의사유에 해당하지 않는 경우

(가) 가압류의 목적재산이 채무자의 소유에 속하지 않는다든지, 유체동산가압류명령에 의하여 공장저당의 목적이 된 기계를 집행한 경우 등과 같은 집행의 하자는 집행권원으로서 보전처분의 효력에는 아무런 관계가 없으므로 이의사유가 될 수 없고, 위와 같은 사유는 제3자이익의 소나 집행에 관한 이의로써 다투어야 한다.

(나) 또한 실무상 채권가압류에서 가압류된 채권의 부존재 등을 이유로 채무자나 제3채무자가 이의하는 경우가 있는데, 이 경우 이의의 이익이 없으므로 이의신청을 각하하여야 한다는 것이 판례의 태도이다(대판 1967. 5. 2. 67다267). 실무례는 위와 같은 사유에 기한 이의신청에 대하여 이의신청을 배척하는 한편 당초 가압류결정을 인가하는 경우와 단순히 이의신청을 각하하는 경우로 나누어져 있으나, 가압류이의신청이 이익이 없는 경우에는 보전처분의 당부에 대한 판단에 들어갈 여지가 없으므로 주문에서 따로 인가 판단을 할 필요 없이 이의신청을 각하하는 실무례가 법리상으로 더 타당하다.

(11) 이의사유가 기재되지 않은 경우의 처리

이의신청서에 이의사유가 기재되어 있지 않거나 이의사유가 구체적이지 않은 경우라 하더라도 실무상 이의신청서는 민사소송의 답변서에 해당하므로 구체적인 이의사유를 적지 않아도 위법하지는 않으므로, 이의신청을 기재하여 제출하라는 보정명령에 응하지 아니하였다는 이유로 이의신청서 각하명령을 할 수는 없다.

라. 접수

이의신청이 제출되면 이를 신청사건으로 접수하여 사건번호를 부여하고 신청사건부에 전산등록한다. 다만 그 기록은 따로 조제하지 않고 보전처분신청사건에 합철하며 그 표지의 관련사건번호란에 이의사건번호를 기재한다(재민 91-1). 일반적으로는 표지의 당사자란에 따로 이의신청인을 표시할 필요는 없으나 채무자들 중 일부만 이의신청한 경우에는 표시해 주는 것이 좋다.

한편 채무자들이 한꺼번에 이의신청을 하지 않고 채무자들 중 일부가 이의신청을 한 후 순차적으로 다른 채무자들이 이의신청을 하여 여러 건의 이의신청이 접수되는 경우에는 일단 별도의 사건으로 접수하되 병합해서 처리한다.

마. 이의신청의 취하

(1) 채무자는 이의신청에 대한 재판이 있기 전까지 채권자의 동의 없이 이의신청을 취하할 수 있다(민집 285조 1항, 2항, 301조).

(2) 이의신청의 취하는 서면으로 하여야 하나 변론 또는 심문기일에서는 말로 할 수 있다(민집 285조 3항). 보전처분신청의 취하와 마찬가지로 취하간주규정은 적용되지 아니하므로, 채무자가 이의기일에 2회 이상 불출석하더라도 이의신청이 취하된 것으로 볼 수 없다. 이의신청서를 송달한 후에 이의신청이 취하된 경우에는 취하의 서면을 채권자에게 송달하여야 하고, 변론 등 절차에서 말로 취하한 경우에 채권자가 그 기일에 출석하지 아니한 때에는 그 기일의 조서 등본을 송달하여야 한다(민집 285조 4항, 5항).

(3) 이의신청이 취하되면 보전처분 당시의 상태로 돌아간다. 채무자는 이의신청 취하 후에 다시 이의신청을 할 수 있다. 민사집행법 개정 당시에 이의신청의 취하 후에는 다시 이의할 수 없도록 하는 방안이 제시되었으나 이의신청취하 후에 다시 이의신청을 할 수 없도록 하는 것은 절차의 발전적 성격에 반할 뿐만 아니라 재이의의 실무례도 찾기 어려우므로 구태여 재이의의 금지를 명문화할 필요가 없다는 이유로 채택되지 않았다.

바. 보전처분신청취하 및 집행해제 시 이의사건의 처리

이의사건의 진행 중에 보전처분을 취하한 경우에 과거에는 이의신청으로써 취소할 대상이 남아있지 않게 되어 신청의 이익이 없어 부적법함을 이유로 각하하는 실무례도 있었으나, 현재는 별도의 결정 없이 이의사건은 보전처분취하 및 집행해제신청으로 실효된다고 보아 중국내역에서 “보전처분취하로 인한 실효”로 입력하고 보전처분사건을 중국시키고 있고, 아래에서 보는 바와 같이 재판사무시스템에도 이를 반영하여 WKA510 중국입력 화면에서 재판부를 선택 후 “이의신청사건 조회”를 체크한 다음 사건번호 입력 후 결과에서 [(818)보전처분취하로 인한 실효]를 선택하면 된다.

6. 심리

가. 심리방식

(1) 심리방식의 변경

이의신청이 있는 때에는 법원은 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일을 정하여야 한다(민집 286조 1항). 이는 당사자 쌍방을 대등하게 취급하여야 한다는 요청에 따라 최저한의 절차보장을 명확히 한 것이다.

(2) 심문

심문에 관한 규정으로는 민사소송법 134조가 있는데, 심문이란 법원이 당사자 등 사건
170의 관계인에게 별개로 또는 동시에 서면 또는 말로 진술할 기회를 부여하는 절차를 말한다. 심문은 당사자의 주장청취, 석명처분으로 행하기 때문에 그 자체는 증거조사로서의 성질을 갖지 않는다. 그러나 심문결과가 심문 전체의 취지로서 심증형성에 영향을 미칠 수 있다. 심문기일은 반드시 공개법정에서 열지 않아도 되므로 심문실·준비절차실 등에서도 진행할 수 있다. 이의심리에서는 원칙적으로 심문기일로 진행함이 타당하다. 특히 합의

부의 경우에는 수명법관이 심문절차를 주재할 수 있다(민소 160조, 165조). 증인신문이나 당사자신문을 할 필요가 있는 사건의 경우에는 변론기일로 진행하여야 한다.

(3) 변론

민사집행법 286조 1항의 변론기일은 임의적 변론이고, 당사자가 주장하거나 제출한 증거자료에 대하여 석명이 필요한 경우 법원의 재량으로 열린다. 그러므로 임의적 변론으로 열린 변론기일에는 구술주의·직접주의의 적용이 없고, 신청서 그 밖에 당사자의 주장을 적은 서면(주장서면)은 진술하지 않아도 재판자료로 되고, 서증도 제출만으로 재판자료가 된다. 임의적 변론은 석명을 위하여 행하여지기 때문에 당사자가 출석하지 않았다 하여 불이익하게 취급할 수 없으므로, 민사소송법 148조(진술간주), 150조(자백간주), 268조(취하간주)는 적용되지 않는다. 또 직접주의의 적용도 없기 때문에 판사의 변경에 의한 변론갱신도 필요 없다.

심문기일의 경우에는 재판공개가 필요하지 않은 반면 변론기일의 경우에는 재판공개가 필요하다는 점, 심문기일의 경우에는 참고인 심문만 가능하고 증인신문이나 당사자 신문은 불가능한 반면 변론기일의 경우에는 증인신문이나 당사자 신문도 가능하다는 점에서 변론절차와 심문절차는 차이가 있다.

(4) 원칙적으로 심문기일로 진행

임의적 변론은 심문보다 절차적 보장에 더 충실하지만, 위에서 본 바와 같이 필수적 변론과는 성질이 상당히 다르다. 그리고 심문의 경우에도 당사자를 대동하도록 하는 절차가 정비되어 임의적 변론과 큰 차이가 없다. 더욱이 2005년 개정 전 본법 아래에서 이의사건 심리의 장기화 원인이 형식적이고 경직화된 변론절차에 기인하는 측면이 많았다는 점을 고려하면 이의심리에서는 원칙적으로 심문기일로 진행함이 타당하고, 현재 실무상으로도 심문기일로 진행하고 있으며, 임의적 변론기일로 진행하는 경우는 찾아보기 어렵다.

171

나. 송달과 통지

(1) 이의신청서의 송달

민사집행규칙 206조 2항은 이의신청서 부분을 채권자에게 송달하도록 규정하고 있다. 이의신청을 한 채무자에게 채권자의 주소를 확인하여 보정할 의무가 있는 것이 아니고, 설사 채무자가 채권자의 구속 상태를 알고서 이를 법원에 알리지 않았더라도 채권자에 대한

공시송달을 위법이라고 할 수 없다(대판 1992. 4. 14. 92다3441). 가처분사건의 채권자인 회사가 송달장소 변경사실을 신고하지 아니하여 종전 송달장소로의 송달이 불능된 경우, 기록에 있는 법인등기사항증명서상의 본점 소재지나 대표이사의 주소지로 송달해 보지 아니한 채 곧바로 발송송달을 하는 것은 잘못이다(대판 2001. 8. 24. 2001다31592).

(2) 기일의 지정

이의절차는 결정절차이기 때문에 서면공방 등의 절차 없이 1차 기일을 이의신청서 접수일부터 신속하게 정하여 진행함이 상당하다.

(3) 기일의 통지

기일통지는 심문의 경우뿐만 아니라 변론을 여는 경우에도 전화·팩시밀리·보통우편 또는 전자우편(e-mail)으로 하거나, 그 밖에 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있다(민집 23조, 민소 167조, 민소규 3조 1항, 45조). 통지의 방법이 상당한지 여부는 최종적으로 법원이 판단하지만 통지의 사무를 실제로 담당하는 것은 법원사무관등이기 때문에 법원사무관등의 판단에 의하여 통지의 방법을 선택한다.

- 172 상당한 방법으로 통지를 한 경우 상대방에게 도달하지 않았다는 것이 명백한 경우 이외에는 통지의 절차가 있었던 이상 법원사무관등은 기록상 이것을 명백히 표시하여야 한다(민소규 3조 2항). 기록상 표시는 조서에 기재할 필요는 없지만, 간이송달보고서[전산양식 A1407]에 통지의 방법과 일시를 적어 기록에 편철하거나 간이송달보고서의 사본 또는 부분 등을 기록에 편철하는 방법 등 적당한 방법을 선택하여 기록에 표시하면 된다. 그러나 송달에 의한 통지가 있었던 때에는 송달현황목록에 의하고, 당사자가 출석하고 그 기회에 다른 기일이 고지된 경우에는 그 사실을 조서에 적는 것으로 족하다.

다. 기일의 진행

(1) 당사자의 심문기일 출석 불요

심문은 반드시 당사자 쌍방의 출석을 요하지 않는다. 민사집행법 286조도 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일을 최저 1회 열지 않으면 안 되는 것으로 정하고 있을 뿐 항상 당사자 쌍방의 출석을 보장하는 것으로 하고 있지 않다. 그러므로 가능한 쟁점이 복잡하지 아니한 사건은 1회의 대심적 심문기일만 진행하고 심문을 종결하되, 모든 심리자료가 현출된 경우에는 심문종결일에 심리종결선언을 하고, 추가적인 자료가

제출되어야 하는 경우에는 별도의 심리종결일을 정하는 것이 바람직하다. 이와 달리 쟁점이 복잡한 사건의 경우에는 심문을 속행할 수는 있으나, 쟁점이 정리될 때까지 심문기일을 추정하는 것은 이의제도의 취지와 보전소송의 성질에 비추어 보면 바람직하지 않다.

(2) 법원사무관등의 심문기일 참여

이의사건의 심리에서는 변론이 열리지 않은 채 심문에 의하여 심리가 이루어져도 민사소송법 160조에 따라 변론조서에 관한 152조가 준용되어 법원사무관등에 의한 심문조서작성은 필수적이기 때문에 기일에는 원칙적으로 법원사무관 등이 출석하는 것이 필요하다. 그러나 재판장은 심문을 녹음하거나 속기하는 경우 그 밖에 이에 준하는 특별히 필요하다고 인정하는 경우 법원사무관등을 참여시키지 아니하고 기일을 열 수 있다(민집 23조, 민소 152조 1항 단서). 이러한 경우에는 법원사무관등은 그 기일이 끝난 뒤에 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하고, 그 취지를 덧붙여 적어야 한다(민집 23조, 민소 152조 3항).

173

(3) 보전처분을 발령한 법관의 주재

보전이의·취소절차를 보전처분을 발령한 법관이 주재하는 것이 적정한지 여부가 문제된다. 이에 관하여 동일한 법관이 심리하게 되면 보전처분에서 확신에 도달한 법관은 이의 사건에 관하여 예단을 가질 위험이 있으므로, 다른 법관이 보전이의·취소사건을 심리하는 것이 채무자를 납득시키기에 용이하다는 견해도 있으나, 보전이의·취소절차는 상소심절차와는 달리 동일한 심급에서 보전신청의 당부를 다시 심리하는 것이고, 보전처분절차에 관여한 법관이 보전이의·취소절차에 관여하면 사건에 관하여 예비지식을 갖고 있으므로 신속한 절차진행이 가능하다는 이유로 현재 실무에는 원칙적으로 보전처분을 발령한 법관이 보전이의·취소절차를 담당하고 있다.

(4) 조서의 작성 및 생략

심문 또는 임의적 변론에서는 변론주의·직접주의가 적용되지 않고, 주장서면과 서증은 제출하기만 해도 재판자료가 되므로, 주장서면의 진술이나 서증의 제출·조사 여부를 적지 않아도 된다. 법원사무관등은 재판장의 허가를 받아 증인·참고인·당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과의 기재를 생략할 수 있다(민집 23조, 민소 155조, 160조, 민소규 32조). 신속한 절차진행을 위하여 이러한 조서기재의 생략을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 다만 쟁점이 복잡한 경우, 심리가 곤란하게 될 우려가 있는 경우, 심리종결까지 상당한 시일이 소요될 것으로 예상되는 경우, 판사의 교체가 예상되는 경우, 이의·취소절차에서

불복이 예상되는 경우 등에는 조서기재를 함이 상당하다.

재판장의 허가가 있는 경우에는 바로 그 취지를 당사자에게 통지하여야 하고, 당사자가
174 통지받은 날부터 1주 안에 이의를 제기하면 법원사무관등은 조서를 작성하여야 한다. 통
지는 상당한 방법으로 하면 족하고, 통지의 취지와 방법은 기록에 표시하여야 한다(민집
23조, 민소규 3조 1항). 실무상으로는 심리를 종결할 때에 바로 그 자리에서 당사자들로부터
조서의 기재를 생략하는 데 이의가 있는지 여부를 확인하여 이를 조서에 적는 것이
편리하다.

○○ 법원

변론(심문)조서

1차

사 건 20 카단

기 일 20 . . . :

판 사

장 소 제 호 법정

공개여부 공개

법원주사

고지된 심문기일①

다음기일 20 . . . :

심리종결일 20 . . . ②

사건과 당사자의 이름을 부름

채권자 출석

채무자 출석

채권자③

채권자가 채무자와 가처분신청서의 신청이유 제1항에 기재한 계약을 체결한 것은
20 . . . 이다.

채무자④

위 계약은 20 . . . 해제의 의사표시로 해제되었다. 채권자가 제출한 이행각서는
위조되었다.

증거관계 별지와 같음(채권자 증인 등)⑤

출석한 쌍방에게 심리종결일 고지②

법원주사 ㉑

판 사 ㉑

《주요 기재 사항》

175

① 고지된 다음기일

변론기일 또는 심문기일 중 어느 것인지를 명백히 표기한다. 법원은 필요에 따라 변론기일과 심문기일을 서로 번갈아가면서 기일을 진행할 수도 있다.

② 심리종결일

기일에서 상당한 유예기간을 두고 심리를 종결할 기일을 정한 때에는 그 심리종결일을 적고(민집 286조 2항), 출석한 당사자에게 이를 고지하였다는 문구를 적는다. 다만 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일에서는 즉시 심리를 종결할 수 있으므로, 이때에는 조서말미에 심리종결이라고 적고, 심리종결일을 적지 않는다.

③, ④ 당사자의 진술

“채권자 ○○법원이 20 . . .에 한 가처분결정을 인가한다는 결정을 구하고 가처분신청서 진술”, “채무자 위 가처분결정을 취소하고, 채권자의 가처분신청을 기각한다는 결정을 구함”이라고 적지 않는다. 결정절차에서는 이의신청서 등에 기재되어 있으면 기일에 진술하지 아니하여도 재판자료가 되기 때문이다. 대신 채권자나 채무자가 기일에서 주장하는 내용, 또는 서증의 성립을 적극적으로 다투거나 그 제출을 철회하는 진술을 하는 때에는 이를 간략하게 적는다.

⑤ 증거관계

서증은 법원에 제출하는 것으로 재판자료가 되고, 서증목록도 조서의 일부가 되지 않으므로 증거관계에서 기재하지 않는다.

(5) 심리의 분리·병합

이의사건에서도 민사소송법 141조 규정을 유추하여 심문을 병합하여 심리할 수 있다. 심문에서 사건을 병합하는 경우에는 변론의 병합과 같은 방식으로 결정서 또는 심문조서를 작성하여 기록에 편철할 필요가 있고, 심문의 병합 후에는 변론의 병합이 된 때와 마찬가지로 주장과 소명이 공통되는 것으로 진행한다.

라. 주장과 소명

176

(1) 증명의 정도

증거의 증명력은 보전처분신청 당부를 심리할 때와 마찬가지로 증명 아닌 소명에 의한 다(대판 1965. 5. 18. 65다174). 소명방법으로 제출한 서증은 채권자가 제출한 것을 “소

갑 제○호증”, 채무자가 제출한 것을 “소을 제○호증”이라고 한다.

(2) 증인신문

선서에 의한 정식의 증인신문을 요하는 경우에는 변론을 열어 증인신문을 하여야 한다. 다만 심리를 신속하게 행하기 위해 서증조사를 중심으로 증거조사를 하되, 인증의 조사는 서증에 의하여 대체할 수 없다고 인정되는 경우에 한하여 단시간에 집중적으로 행하는 것이 바람직하다.

(3) 참고인신문

참고인신문에 대하여는 증인신문과 달리 선서에 관한 민사소송법의 규정이 준용되지 않고 출석요구도 하지 않는다. 따라서 출석요구를 전제로 하는 불출석에 대한 제재 등에 관한 민사소송법 규정도 준용되지 않는다.

(4) 주장서면과 서증의 제출

판결절차에서는 준비서면과 서증을 다시 변론에서 진술·제출하여야 재판자료가 되고, 또 변론에 진술·제출하기 전에 상대방에게 준비서면과 서증이 교부되어야 하므로 상대방은 준비서면과 서증을 교부받을 수 있다. 그러나 결정절차에서는 제출된 서면·서증은 변론에서 다시 제출하지 않아도 그대로 재판자료로 되지만 상대방에게 교부되는 것이 보장되지 않으므로, 상대방의 방어권 보장을 위해 주장서면과 서증이 교부된 다음에 심리를 진행할 필요가 있다.

177 이에 관하여 ‘보전처분 신청사건의 사무처리요령’ 12조(재민 2003-4)는 “보전처분에 대한 이의신청이 있는 때에는 법원은 변론기일통지서 또는 심문기일통지서를 채권자에게 송달함과 동시에 채권자로 하여금 채무자 수만큼의 신청서 부분을 제출하도록 통지하고, 제출된 신청서 부분을 채무자에게 송달하여야 한다. 다만 보전처분에 대한 심리 과정에서 이미 신청서 부분을 채무자에게 송달한 경우에는 그러하지 아니하다(1항). 법원은 1항 본문의 규정에 따라 제출된 신청서 부분을 채무자에게 송달하여야 한다(2항).”고 규정하고 있다.

채무자가 참여할 수 있는 심문기일 또는 변론기일이 열린 후에 제출되는 주장서면과 서증에 대하여는 상대방의 수와 같은 수의 부분(주장서면 원본은 기록편철용, 부분은 상대방 교부용)을, 서증을 제출할 때에는 상대방의 수에 1을 더한 수의 사본(서증사본 중 1부는 원본과 비교 후 기록편철용, 나머지는 상대방 교부용으로 사용)을 함께 제출하여야 하고, 법원사무관등은 제출받은 부분 또는 사본을 상대방에게 송달함이 바람직하다.

재판장·수명법관은 기일에 채권자 또는 채무자가 주장서면 부분이나 서증사본을 제출하였는지를 확인하고, 제출하지 아니하는 경우에는 제출을 촉구할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 이에 응하지 않는 경우에는 제재를 가할 방법이 없으므로 재판장은 상대방의 하여금 기록에 편철된 주장서면이나 서증을 복사하도록 하고, 기일진행에 관하여 상대방의 의견을 물어 그 의견에 따르는 것이 바람직하다. 왜냐하면 기일진행을 지연하기 위해 고의적으로 주장서면 부분이나 서증사본을 제출하지 않는 경우가 있을 수 있고, 그 경우에는 그대로 기일을 진행하는 것이 상대방의 이익에 부합될 수 있기 때문이다.

(5) 목록의 작성 불필요

서증은 제출함으로써 재판자료가 되어 조서의 일부가 되지 않고, 민사 등 증거목록에 관한 예규(재민 2004-6)가 적용되지 않으므로, 서증·증인 등 목록을 작성할 필요는 없다.

마. 신청취지와 피보전권리의 변경

178

(1) 신청취지의 감축

신청취지의 감축은 신청의 일부 취하로서 채권자는 이의절차에서 채무자의 동의 없이도 할 수 있다.

(2) 신청취지의 확장 또는 교환적 변경

특별한 사정이 없는 한 보전처분에 대한 이의절차에서 채권자가 신청취지를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없다(대결 2010. 5. 27. 2010마279).

(3) 피보전권리의 변경

보전처분신청은 긴급한 필요에 따른 것으로서 피보전권리의 법률적 구성과 증거관계를 충분히 검토·확정할 만한 시간적 여유가 없이 이루어지는 사정에 비추어 보면, 당사자가 권리 없음이 명백한 피보전권리를 내세워 보전처분신청을 한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 청구의 기초에 변경이 없는 범위 내에서는 보전처분의의절차에서도 피보전권리를 변경할 수 있다(대결 2009. 3. 13. 2008마1984). 따라서 소유권이전등기말소청구권을 피보전권리로 하여 처분금지가처분결정을 받은 다음 청구의 기초에 변경이 없는 범위 안에서 그 가처분의의절차에서 가처분신청이유에 예비적으로 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권을 추가할 수 있다(대판 1982. 3. 9. 81다1221). 또한 변경에 의하여 피보전권리로 추가되는 권리가 보전처분의 재판 당시 아직 발생하지 아니한 권리라 하더라도 이를 피보전

권리로 변경할 수 있다(대판 1996. 2. 27. 95다45224). 그러나 보전소송에서도 처분권주의·변론주의가 적용되므로, 선행 매매계약의 매매대금 지급청구권을 피보전채권으로 하는 가압류결정을 후행 매매계약에 기한 잔대금 및 그 지연배상금의 범위 내에서 인가하고 그 초과 부분을 취소하는 것은 허용되지 않는다(대판 2009. 11. 26. 2008다23224).

또한 원결정 당시 보전처분신청을 일부 인용하고 일부 기각한 경우, 일부 기각된 부분은 항고의 대상이 되는 것이지 이의절차에서 다루어질 것은 아니다.

179 바. 심리의 종결

(1) 의의

민사집행법 286조 2항은 “법원은 심리를 종결하고자 하는 경우에는 상당한 유예기간을 두고 심리를 종결할 기일을 정하여 이를 당사자에게 고지하여야 한다. 다만 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일에는 즉시 심리를 종결할 수 있다.”고 규정하고 있다. 심리종결선언은 심리종결이 당사자가 예상하지 못한 시기에 이루어지는 것을 방지하기 위한 규정이다. 구법에서는 이의절차가 변론을 거친 판결절차로 진행되므로 심리를 종결할 때에는 반드시 변론종결의 고지가 필요하였지만, 개정법에서는 이의절차가 결정절차로 변경되어 1회의 임의적 변론 또는 심문만이 필수적일 뿐 나머지 절차는 법원의 재량에 맡겨진 상태이므로 심리종결의 시기가 반드시 명확한 것은 아니다. 그리하여 당사자로서는 심리종결의 시기를 예측할 수 없어서 자칫 주장·소명의 기회를 놓치게 될 우려가 있다. 이에 당사자로 하여금 심리종결의 시기를 예측할 수 있도록 하고, 그에 따라 주장·소명의 기회를 충분히 부여하기 위하여 심리종결 전에 미리 그 선언을 하도록 한 것이다.

(2) 심리종결의 방법

민사집행법은 심리종결의 방법으로 2가지를 정하고 있다. 상당한 유예기간을 두고 ‘심리종결일’을 정하거나(민집 286조 2항 본문), 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일에 즉시 심리를 종결하는 선언을 하는 것이다(민집 286조 2항 단서). 실무상 심문기일에서 심리종결을 선언하는 것을 원칙으로 하되, 당사자가 추가로 주장·소명자료의 제출을 원하는 경우에 한하여 예외적으로 상당한 유예기간을 두고 심리종결일을 지정하고 있다.

심리종결일은 역년상 일정한 날을 지정하는 것이므로 유예기간을 정할 수 없고, 양당사자에게 일률적으로 지정하여야 하므로 채권자에게는 2019. 10. 5., 채무자에게는 2019. 10. 20.로 정하는 방식은 허용되지 않는다.

(3) 주체

180

심리종결선언의 주체는 법원이다. 수명법관에 관하여는 이를 부정하는 견해도 있으나, 실무상 수명법관이 심문기일에 심리종결을 선언하는 경우도 있다. 통상 당사자가 기일에 출석한 때에 재판장(또는 수명법관)이 선언하기 때문에 별도로 통지할 필요는 없다. 문제는 기일에 불출석한 당사자인데, 심리종결선언의 고지를 받지 못한 것은 불출석한 당사자의 책임이고 법원이 별도로 통지할 의무가 없다. 이와 달리 기일 밖에서 별도로 하는 심리종결일의 지정은 결정의 형식으로 하고 상당한 방법으로 고지하면 족하다.

(4) 심리종결일 지정의 효과

심리종결일까지 제출된 자료만이 이의사건의 판단자료가 된다. 그러나 법원은 심리종결일까지 제출된 자료에 불명확한 점이 있는 경우에는 종결일 이후에도 당사자에게 석명을 구할 수 있다. 법원이 심리종결일 후에 제출된 자료에 의하여 다시 심리를 행할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 심리를 재개할 수 있다. 즉 심리종결일 이전에는 민사소송법의 기일변경 규정(민소 165조)을 준용하여 심리종결일을 변경할 수 있고, 심리종결일 경과 후에는 민사소송법의 변론재개에 관한 규정(민소 142조)을 준용하여 심리를 재개할 수 있다.

7. 재판

가. 재판의 형식

이의신청이 적법하면 심리종결 당시의 사정을 기준으로 보전처분신청의 당부를 판단하고, 재판은 변론을 열었든 열지 않았든 언제나 결정의 형식에 의한다(민집 286조 3항). 판결의 경우에는 기판력의 표준시를 명확하게 하기 위하여 변론종결일을 기재하고 있으나, 보전처분이의결결정의 경우에는 기판력이 존재하지 아니하므로 보전처분이의결정문에 별도로 심리종결일을 기재할 필요는 없다.

나. 결정이유의 기재

181

결정에는 이유를 적어야 하지만, 변론을 거치지 아니한 경우에는 이유의 요지만을 적을 수 있다(민집 286조 4항). 결정에 이유를 적도록 한 것은 비록 이의신청에 대한 재판의 형식이 결정으로 되었지만, 채무자를 철저히 보호하고 불복신청에 대한 재판

으로서의 실질을 확보하기 위한 것이다. 이의신청에 대한 결정의 이유를 적을 때에는 보전처분신청에 대한 결정의 기재 전부 또는 일부를 인용할 수 있다(민집규 203조의3 2항). 임시의 지위를 정하기 위한 가처분결정서에 이유가 상세하게 적혀 있는 경우에 특히 유용하게 활용될 수 있다.

다. 보전처분의결정 정본의 송달

결정 정본은 당사자에게 송달하여야 한다(민집규 203조의4). 일반적으로 결정은 판결과 달리 상당한 방법으로 고지할 수 있지만(민소 221조), 보전처분의결정은 당사자에 대하여 그 내용을 확실히 인식시켜 그 증명방법을 기록에 남겨 놓을 필요가 있는 점, 법개정 전에도 실무상 결정을 송달로 고지해 온 점, 불복기간을 명확히 기산할 필요가 있는 점 등에 비추어 송달함이 상당하기 때문이다.

라. 이송결정

채무자가 관할위반을 이유로 이의신청을 하였고, 법원이 사건을 심리한 결과 관할을 위반한 것으로 밝혀지면, 관할위반을 이유로 보전처분을 취소하되, 채권자의 신청을 기각하지 않고 사건을 관할법원으로 이송하여야 한다. 주문례는 다음과 같다.

1. 위 당사자 사이의 ○○법원 20○○카단○○○ 가처분신청사건에 관하여 위 법원이 20 . . .에 한 가처분결정을 취소한다.
2. 위 가처분신청사건을 ○○법원으로 이송한다.
3. 소송비용은 채권자가 부담한다.

182 마. 각하결정

이의신청권이 없는 자가 이의신청을 한 경우라든지 이의의 이익이 없는 경우와 같이 이의신청이 부적법하면 이의신청을 각하한다. 이 경우에는 보전처분의 당부에 대한 판단에 들어갈 여지가 없으므로 주문에서 따로 인가의 판단을 할 필요가 없다. 주문례는 다음과 같다.

1. 이 사건 이의신청을 각하한다.
2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

바. 인가결정

심리종결일을 기준으로 보전처분신청이 실체적 요건과 절차적 요건을 충족하여 보전처분을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 보전처분의신청은 이유 없으므로 보전처분을 인가한다. 주문에서 채무자의 이의신청을 기각한다는 결정을 별도로 할 필요는 없다. 가압류결정의 청구금액 중 일부만을 피보전채권으로 인정하면서도 그 가압류결정 전부를 인가하면 위법하다(대판 1996. 2. 13. 95다34545). 주문례는 다음과 같다.

1. 위 당사자 사이의 이 법원 2000카단○○○ 부동산가압류 신청사건에 관하여 이 법원이 20 . . . 에 한 가압류결정을 인가한다.
2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

사. 취소·변경결정

(1) 의의

이의신청이 이유 있으면 보전처분을 취소·변경하고, 채권자의 보전처분신청을 기각·각하한다. 주문례는 다음과 같다(4항은 아래에서 보는 효력유예선언을 하는 경우에만).

1. 위 당사자 사이의 이 법원 2000카단○○ 부동산처분금지가처분 사건에 관하여 이 법원이 20 . . . 별지 목록 기재 부동산에 대하여 한 가처분결정을 취소한다.
2. 채권자의 가처분신청을 기각한다.
3. 소송비용은 채권자가 부담한다.
- (4. 제1항은 채권자가 이 결정을 고지받은 날로부터 10일이 경과하여야 효력이 생긴다.)

183

피보전권리의 일부(대결 2008. 7. 10. 2008마260), 복수의 보전집행대상 중 일부(대결 2008. 5. 9. 2007마696), 보전집행대상인 공유지분 중 일부(대결 2008. 2. 28. 2007마274)에 한하여 이의사유가 인정되는 경우에는 보전처분 중 일부를 특정하여 취소·변경하여야 한다.

취소·변경결정에서 신청이 가분이면 원결정의 일부인가, 일부취소와 함께 취소부분에 대한 신청을 기각한다. 신청이 불가분이면 원결정에 대한 취소의 주문이 필요 없이 바로 변경의 한도 내에서 새로운 보전처분을 발령하는 방법으로 한다. 다만 이때 보전처분의 실질을 변경함이 없는 경우에는 예외이나 피보전권리의 일부가 이유 없는 경우와 가처분에서 채권자가 구하는 구체적 처분을 실질적으로 일정한 한도에서 제한하는 가처분명령을 발령하는 경우 등에서는 신청의 일부를 기각하여야 한다.

취소나 변경은 원결정의 어떠한 부분에 대하여도 할 수 있으나 보전처분의의절차는 채무자의 신청에 의하여 개시된 불복절차로서 불이익변경금지원칙이 적용되므로(민집 23조, 민소 415조), 이의재판에서는 채무자에게 불리하게 보전처분을 변경할 수 없으므로 원결정의 보증액을 증액하고 해방공탁금을 낮출 수는 있어도 그 반대는 허용되지 않는다. 한편 1심법원이 가압류명령을 취소하는 주문을 내면서 동시에 채권자의 가압류신청을 기각하는 주문을 내지 아니하였다고 하더라도, 이는 제1심이 당사자에게 오해를 불러일으킬 수 있는 정도의 불명확한 판결 주문을 낸 것에 불과하고, 재판이 탈루된 것이라거나 중국재판을 하기에 앞서 선결문제에 관하여 중간재판을 한 것이라고는 볼 수 없다(대판 1994. 12. 27. 94다38366).

184 일부 취소 또는 변경은 통상 가압류의 경우에는 청구채권의 축소변경, 가압류된 재산의 일부에 대한 가압류의 취소, 해방공탁금의 감액, 담보의 변경 또는 증액 등으로 나타날 것이고, 가처분의 경우에는 작위의무의 변경(임시로 지급하여야 할 금액의 감액 등), 부작위의무의 변경(야간에 제한되는 소음의 한도 변경), 가처분대상의 축소, 담보의 변경 또는 증액 등이 가능할 것이다.

(2) 효력유예선언

보전처분을 취소하는 결정은 판결절차와 달리 결정의 고지에 의하여 바로 효력이 생기므로, 이 결정에 의하여 채무자는 바로 집행의 취소를 구할 수 있다. 채권자는 이 결정에 대하여 즉시항고를 제기할 수 있지만 집행정지의 효력이 없기 때문에(민집 286조 7항 후문), 채무자에 의하여 집행의 취소절차가 완료된다면 즉시항고가 인용되어도 보전의 목적을 달성할 수 없게 되는 경우가 발생한다. 이러한 사태를 피하기 위해 채권자는 즉시항고를 제기함과 더불어 보전처분을 취소하는 결정의 효력정지를 신청하여야 하는데(민집 289조), 이러한 효력정지신청의 기회만이라도 보장하기 위해 보전처분의 취소결정을 한 법원이 직권으로 2주를 넘지 않는 범위 내에서 효력을 유예하는 선언을 할 수 있도록 하였다(민집 286조 6항). 다만 보전처분을 취소하는 결정은 바로 효력이 생기는 것이 원칙이고, 종래 보전처분을 취소하는 판결을 하는 경우에도 가집행선고를 붙이는 것이 원칙이었으므로, 새로 도입된 효력유예선언은 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 활용하는 것이 바람직하다. 이러한 효력유예선언제도는 제소기간경과를 이유로 한 보전처분취소를 제외한 나머지 보전처분취소의 경우에도 준용된다(민집 288조 3항).

주문례는 앞서 본 취소·변경결정 주문례 4항과 같다.

(3) 보전처분의 취소·변경결정에 따른 집행취소

보전처분을 취소·변경하는 결정이 발령되면(효력유예선언이 있는 경우에는 그 유예기간의 경과 후) 보전처분은 당연히 취소·변경되는 효력을 가져오지만, 이로써 이미 행한 집행의 효과가 상실되는 것은 아니고 채무자는 그 결정 정본을 집행기관에 제출하여 집행을 취소를 구하여야 한다. 집행기관은 결정에 효력유예선언이 있는 경우 송달통지서를 통하여 효력유예기간이 경과하였는지를 확인하고 집행취소절차를 취하여야 한다. 채권자는 효력유예기간 내에 효력정지결정을 받아 집행기관에 제출하여야 집행을 취소를 면할 수 있다. 185

보전처분의 내용이 축소변경된 경우, 그 내용이 등기사항(예를 들면 가압류 청구금액의 변경)일 때에는 이의나 취소의 재판을 한 법원의 법원사무관등은 변경내용을 등기관에게 축락하여 등기하도록 하여야 한다. 이 경우 등기관은 가압류 청구금액 등의 변경을 부기등기의 방법으로 한다(등기예규 1023호 참조). 제3채무자가 있는 경우에는 집행취소통지서[전산양식 A4317]를 제3채무자에게 송달하여야 한다(민집규 160조 1항, 213조 2항).

아. 추가담보제공을 조건으로 한 인가결정

(1) 의의

민사집행법은 보전처분을 인가하는 경우 법원은 당사자에게 적당한 담보의 제공을 명할 수 있도록 규정하고 있다(민집 286조 5항, 301조). 이와 같은 규정을 근거로 채무자가 보전처분에 대하여 이의를 제기한 경우 채권자가 추가로 담보를 제공하는 것을 조건으로 보전처분을 인가하는 것을 추가담보제공조건부 인가결정이라고 한다.

이 결정은 추가담보제공조건부로 보전처분을 인가한 것이므로 변경결정의 일종이다. 이는 실질적으로 보전처분을 채권자에게 불리하게 변경한 것이고, 채무자의 이의신청을 전부 받아들이지 아니한 것이므로, 채권자와 채무자는 위 결정에 대하여 즉시항고를 제기할 수 있다. 그러나 즉시항고는 집행정지의 효력이 없으므로(민집 286조 7항), 채권자가 즉시항고를 제기하더라도 효력정지결정이 없는 한 기한 내에 담보를 제공하지 아니하면 보전처분의 효력은 상실된다.

(2) 추가담보의 성질

추가담보도 민사집행법상의 담보이므로 그 제공방법 등은 다른 민사집행법상의 담보와 마찬가지로 보면 된다. 주의할 것은 인가의 경우에 채권자는 보전처분 발령 시에 이미 담

보를 제공하고 있으므로 새로이 명하는 추가담보에 이미 제공된 담보금액이 포함되어 있는지 여부를 명백히 표시하여야 한다는 점이다.

법원이 추가담보제공조건부로 보전처분을 인가한다는 의미는 채권자가 정해진 기간 내에 추가담보를 제공한 경우에 한하여 보전처분의 효력을 존속시킨다는 것이다. 따라서 담보의 미제공은 보전처분의 효력을 소멸시키는 해제조건이다. 한편 추가담보는 인가·변경 재판의 효력발생조건은 아니다. 보전처분의 효력을 존속시켜서 보전처분신청의 목적을 계속 달성하기 위해서 채권자는 기간 내에 담보를 제공하였다는 증명서를 집행기관에 제출하여야 한다. 채권자가 기간 내에 담보를 제공하지 아니한 경우나 채권자가 기간 내에 담보를 제공하였더라도 이를 증명하는 서면을 기간 내에 집행기관에 제출하지 아니한 경우에는 보전처분의 효력 존속조건을 성취하지 못하였으므로 보전처분의 효력은 상실된다.

(3) 주문례

추가담보의 성질을 보전처분의 효력을 존속시키는 조건으로 파악하는 견해에 의한 주문례는 다음과 같다.

채권자가 이 결정문 정본을 송달받은 날부터 7일 이내에 채무자를 위하여 추가로 ○○원을 담보로 제공하는 것을 조건으로, 채권자와 채무자 사이의 ○○지방법원 20○○카단○○ 채권가압류결정을 인가한다.

위 주문례 다음에 “채권자가 위 기간 내에 제1항 기재 담보를 제공하지 아니하면, 위 가압류결정을 취소한다.”는 주문례를 추가하여야 한다는 주장도 있지만, 대부분의 실무례는 위와 같은 추가기재는 무익적 기재사항이라고 보아 추가 기재를 하지 않고 있다.

187 (4) 추가담보 미제공 시 채무자의 구제수단

채권자가 담보를 제공하지 아니하면 보전처분의 효력 또는 집행력은 상실되므로, 효력 또는 집행력이 상실된 보전처분에 기하여 보전집행을 유지하는 것은 위법하게 된다. 조건부 인가결정 정본은 민사집행법 49조 1호 소정의 ‘집행처분의 취소를 명한 취지를 적은 재판의 정본’에 해당하므로, 채무자는 집행기관에 위 정본을 제출하여 같은 법 50조에 의하여 집행의 취소를 구하면, 집행기관은 집행을 취소하여 주어야 한다. 그럼에도 불구하고 집행기관이 집행취소를 거부하는 경우 같은 법 16조에 의하여 집행에 관한 이의를 제기할 수 있다. 집행에 관한 이의는 집행법원이 관할법원이 된다. 이의신청은 기일에 출석하여 하는 경우를 제외하고는 서면에 의하여야 하며 이의의 이유를 구체적으로 밝혀야 한다(민집규 15조). 이의신청은 집행개시 후 집행종료 시까지 할 수 있다. 집행이 종료된 뒤에는 이의의 이익이

없으므로 종료 후에 제기된 신청은 부적법한 것으로 보아 각하하여야 한다. 집행절차를 취소하는 결정에 대하여는 채권자가 즉시항고를 할 수 있다(민집 17조). 집행에 관한 이의를 기각하거나 각하하는 결정에 대하여 채무자는 민사집행법 23조 1항, 민사소송법 449조 1항에 의하여 특별항고사유가 있는 경우에 대법원에 특별항고를 제기할 수 있을 뿐이다.

자. 담보제공을 조건으로 한 보전처분의 취소결정

법원은 적당한 담보제공을 조건으로 보전처분을 취소할 수 있다(민집 286조 5항, 301조). 위 담보는 보전처분의 취소 그 자체의 조건이다. 그러나 조건부인가결정과는 달리 담보를 제공하는 기간을 반드시 제한할 필요는 없다. 위 담보는 보전처분의 취소로 인하여 채권자에게 발생한 손해를 담보하기 위한 것이므로, 채권자는 채무자에 대하여 손해배상 청구의 집행권원을 얻어 이에 대하여 집행할 수 있고, 채권자는 위 담보에 대하여 우선권을 가진다.

그러나 강제집행의 목적물이 될 수 없어 장차 강제집행을 보전하기 위한 보전처분인 가압류의 대상도 될 수 없어서 가압류신청이 부적법하다는 이유로 가압류결정을 취소하는 경우에는 가압류취소의 조건으로 채무자에게 담보제공을 명할 수 없다(대결 2012. 11. 188 29. 2012마1647).

담보제공을 조건으로 한 보전처분의 취소결정의 주문례는 다음과 같다.

채무자가 이 결정문 정본을 송달받은 날부터 10일 이내에 채권자를 위하여 ○○원을 공탁하고 이 법원에 그 공탁서를 제출하거나 그 지급에 갈음하는 증권을 제출하는 것을 조건으로 하여, 채권자와 채무자 사이의 이 법원 ○○지방법원 20○○카단○○ 채권가압류결정을 취소하고, 채권자의 가압류신청을 기각한다.

차. 이의결정의 효력

(1) 기판력 부존재

보전소송절차는 피보전권리의 종국적 확정을 목적으로 하는 절차가 아니고 이의절차에서의 피보전권리의 존부에 관한 판단도 어디까지나 보전처분을 발령하는 것이 타당한가를 결정하기 위한 하나의 요건에 불과하기 때문에 보전처분에 대한 이의절차에서의 피보전권리 존부에 대한 판단에 기판력이 생길 여지는 없다(대판 1977. 12. 27. 77다1698). 본안소송을 담당한 법원으로서도 보전처분발령 내지 이의절차에서의 피보전권리에 대한 판단을 고려할 필요가 없다.

(2) 취소결정의 불소급효

보전처분결정을 취소하는 결정은 그 결정의 송달 시부터 장래에 향하여 취소의 효과가 있을 뿐이고, 소급하여 보전처분결정이 아예 없었던 것과 같은 상태로 돌아가는 것은 아니다. 이러한 불소급효는 애초부터 보전처분의 요건을 결하였거나 보전처분 후에 사정변경이 생겨 요건이 소멸한 경우나 마찬가지이다. 처분금지가처분결정이 이의소송에서 취소되었다고 하여 채무자가 가처분결정에 위반하여 취소결정 시까지 한 처분행위를 채권자에게 대항할 수 있게 되는 것은 아니다. 다만 본안소송에서 채무자의 승소가 확정되면 가처분의 처분금지적 효력은 당초부터 없었던 것으로 되어 채무자는 가처분 위반행위의 효력을 주장할 수 있게 된다.

제3절 보전처분의 취소

1. 총론

가. 취소소송의 구조

보전처분의 취소를 구하는 소송은 보전처분의 발령요건의 존부(피보전권리의 존부, 보전의 필요성의 유무)를 다투는 것이 아니라 현재 보전처분을 유지할 수 없는 사유(취소사유)가 존재함을 이유로 하는 것이므로, 적극적으로 그와 같은 사유가 있음을 주장하게 되는 신청인(채무자)이 원고에 대응하는 지위를 갖게 되고, 그 부존재를 주장하는 피신청인(채권자)이 피고에 대응하는 지위에서 방어하게 된다.

취소절차는 일단 유효하게 발령된 보전처분을 보전처분신청절차와는 별개의 절차에 의하여 실효시키는 제도라는 점에서, 당해 보전처분신청절차 내에서 보전처분신청의 당부를 재심사하는 이의제도와 구별된다. 따라서 보전처분을 소송대리인이 신청하였더라도 그 소송위임의 효력이 보전처분취소소송까지 유지되는 것은 아니므로, 취소신청서 및 기일통지서 등은 채권자 본인에게 송달하여야 한다. 또한 보전처분신청절차에서 이루어진 선정당사자 선정행위의 효력은 제소명령신청절차에는 미치나 보전처분취소신청사건에까지 미치지 않는다(대판 2001. 4. 10. 99다49170).

나. 관할법원과 이송

(1) 원칙적으로는 보전처분을 명한 법원의 전속관할에 속한다(민집 288조 2항 본문, 301조). 다만 사정변경 등에 따른 보전처분취소사건의 본안이 이미 계속되어 있는 경우에는 그 본안의 관할법원이 취소사건을 관할한다(민집 288조 2항 단서, 301조). 이때 본안의 관할법원은 원칙적으로 제1심법원이지만 보전처분의 취소신청 당시에 본안소송이 항소심에 계속된 때에는 항소심의 전속관할에 속하며(민집 311조), 보전처분의 취소를 신청할 당시 본안이 계속되어 있으면 족하고 그 취소신청의 심리종결 시까지 본안이 계속됨을 요하지 않는다. 반대로 본안소송이 계속된 일이 있어도 취소신청 당시에 그 계속이 이탈된 때에는 그 본안법원은 관할권이 없다. 항소장을 제1심법원에 제출하는 순간 항소심이 계속한다고 보는 것이 실무이다. 따라서 항소장이 제출되었다가 항소기간의 도과, 인지미침, 송달료미납 등의 이유로 그 후에 항소장이 각하된 경우 항소장이 각하되기 전에 보전처분 취소 신청이 제기되면 본안기록의 송부 여부와 관계없이 취소사건은 항소심의 전속관할에 속한다.

190

제1심법원은 본안판결 선고 후에도 항소장이 접수되기 전에 신청된 취소사건에 관하여 여전히 관할을 가진다.

(2) 한편 당사자가 취소신청을 한 법원과 다른 법원에 본안의 소를 제기한 경우처럼, 취소소송과 본안소송이 다른 법원에서 계속되는 경우가 생길 수 있다. 그럴 경우 민사집행법은 이의신청사건의 이송규정을 준용하여 보전처분취소사건을 관할권이 있는 다른 법원으로 이송할 수 있도록 하였다. 다만 이송받는 법원이 심급을 달리하는 경우에는 이송하지 못한다(민집 290조 1항, 284조, 301조).

이는 보전처분취소사건의 재량이송에 관한 규정으로서 이송받는 법원이 심급을 달리하는 경우에는 취소사건을 본안법원으로 재량이송할 수 없지만, 사정변경에 따른 보전처분 취소소송에서는 심급을 달리하더라도 반드시 이송하여야 하는 경우가 있음을 유의하여야 한다. 즉 앞서 본 바와 같이 보전처분의 취소신청 당시에 본안소송이 항소심에 계속된 때에는 항소심의 전속관할에 속하므로, 사정변경에 따른 보전처분취소신청을 제기할 당시 본안소송이 항소심에 계속된 때에는 본안법원인 항소심만이 관할권을 가지고 있어, 취소소송이 제1심법원에 잘못 제기된 경우에는 관할위반을 이유로 사건은 항소심법원에 이송하여야 한다.

(3) 본안소송이 항소심, 상고심을 거쳐 확정된 경우 이를 이유로 보전처분취소를 신청한다면, 보전처분취소신청 당시를 기준으로 본안이 계속된 법원은 존재하지 아니하므로, 보

전처분을 발령한 법원이 보전처분취소사건의 전속관할권을 가진다.

191 다. 신청과 접수

(1) 신청인

(가) 채무자 및 이에 준하는 사람

보전처분의 취소신청을 할 수 있는 사람은 채무자와 그 일반승계인, 파산관재인 등이다. 채무자는 그 보전처분의 목적물을 다른 사람에게 양도한 후에도 취소신청을 할 수 있다(대판 1962. 9. 27. 62다330). 법인 등 단체의 대표자 및 이사 등을 채무자로 하여 그 직무집행을 정지하고 직무대행자를 선임하는 가처분이 있는 경우 그 후 사정변경이 있으면 그 가처분에 의하여 직무집행이 정지된 대표자 등이 그 가처분의 취소신청을 할 수 있고(대판 1995. 3. 10. 94다56708), 이 경우 종전의 대표자 등이 사임하고 새로 대표자가 선임되었다고 하여도 가처분사건의 당사자가 될 수 없는 법인 등은 그 가처분취소신청을 할 수 없다(대판 1997. 10. 10. 97다27404).

(나) 특정승계인

가처분목적물의 특정승계인은 채권자대위권의 행사에 의하지 아니하고 직접 취소신청을 할 수 있다(대판 2006. 9. 22. 2004다50235, 대결 2010. 8. 26. 2010마818). 가압류 목적물의 특정승계인도 취소신청을 할 수 있다(대판 2014. 10. 16. 2014마1413, 대결 2019. 4. 5. 2018마1075). 신탁법상의 신탁해지로 신탁재산인 부동산의 소유권을 다시 이전받은 위탁자는 수탁자를 채무자로 한 가처분결정에 관하여 사정변경으로 인한 취소신청을 할 수 있는 신청인적격을 가지며, 위탁자로부터 순차로 목적부동산의 소유권을 전득한 사람도 마찬가지로 위 가처분결정에 관하여 사정변경으로 인한 취소신청을 할 수 있다(대판 2006. 9. 22. 2004다50235). 목적물의 일부지분승계인, 예를 들면 부동산에 대한 처분금지가처분결정이 있고 그 결정이 집행된 이후 당해 부동산의 일부지분을 승계한 자는 공유물의 보존행위로서 단독으로 위 부동산 전체에 대한 가처분결정의 취소신청을 할 수 있다.

192 (다) 이해관계인(제소기간 도과의 경우에만)

가압류 집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 않은 것을 이유로 보전처분의 취소를 구하는 경우에는 이해관계인도 신청인이 될 수 있다(민집 288조 1항 후문). 가압류 집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 않은 경우에 이해관계인도 신청권자로 규정한 취지는 채무자의 재산권을 보호하고 미정리등기부의 장기 방치를 방지하고자 하는 데 있다. 이해관계인은 법률상 이해관계인이므로 보전처분취소에 관하여 법률상 이익이 있는 사람은 모두 이

에 포함되고, 보전집행 목적물의 특정승계인뿐만 아니라 그 특정승계인에 대한 채권자도 이해관계인에 해당한다(대결 2014. 10. 16. 2014마1413). 가압류 집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 않은 것이 아닌 다른 사유를 근거로 보전처분의 취소를 구하는 경우에는 이해관계인이 취소신청을 할 수 없다.

가처분의 경우에도 동일하다.

(라) 채무자의 채권자

보전처분의 취소를 신청할 수 있는 권리는 보전처분신청에 기한 소송을 수행하기 위한 소송절차상의 개개의 권리가 아니라 보전처분신청에 기한 소송절차와는 별개의 독립된 소송절차를 개시하게 하는 권리이므로, 제3자로서 채권자대위권을 행사할 수 있는 사람은 보전처분의 채무자를 대위하여 취소신청을 할 수 있다. 본안제소명령의 신청권 또한 제소기간의 경과에 의한 가압류·가처분의 취소신청권을 행사하기 위한 전제요건으로 인정된 독립된 권리이므로, 제소기간의 경과에 의한 가압류·가처분의 취소신청권뿐만 아니라 본안제소명령의 신청권도 채권자대위권의 목적이 될 수 있는 권리이다(대결 1993. 12. 27. 93마1655, 대결 2011. 9. 21. 2011마1258).

(마) 제3자와 제3채무자

채권가압류나 채권의 처분금지가처분에서 제3채무자는 제3자에 불과하므로 취소신청권자가 될 수 없다(대결 1993. 10. 15. 93마1435). 보전집행목적물의 소유권을 주장하는 제3자는 제3자이기의 소에 의하여 구제받을 수 있다. 실무상 전세권가압류나 전당권 또는 전세권이 있는 채권을 가압류한 경우, 전세기간 등이 만료된 후에 부동산소유자가 저당권자 또는 전세권자를 상대로 제기한 저당권 또는 전세권말소등기청구소송이 원고승소로 확정되었으나 이해관계 있는 제3자인 가압류채권자의 승낙을 얻지 못하여 말소등기를 하지 못하고 있음을 이유로 가압류취소를 구하는 경우가 있다. 그러나 이 경우에 부동산소유자로서는 가압류채권자를 상대로 말소등기에 대한 승낙의 의사표시를 구하는 소송이 가능할 뿐 가압류취소신청을 할 수는 없고, 채권가압류사건의 제3채무자로서 민사집행법 291조, 248조 1항의 집행공탁을 한 다음 공탁서와 공탁신고서를 첨부하여 가압류법원의 법원사무관등에게 채권가압류사실의 등기를 말소촉탁하여 줄 것을 신청하는 방법으로 문제를 해결할 수 있다(민집규 167조 4항). 84778

193

(2) 신청의 시기

채무자는 보전처분이 유효하게 존재하는 한 그 취소를 신청할 수 있다. 따라서 이의사건

에서 보전처분을 인가하는 결정이 확정된 후에도 취소신청은 가능하다. 또한 제소기간 경과로 인한 보전처분의 취소신청을 한 후 그 신청을 기각하는 결정이 확정되어도 사정변경에 따른 취소신청은 가능하다. 만족적 가처분에서 그 집행이 종료된 후에는 취소신청의 이익이 없다는 설도 있으나 원상회복이 가능한 이상 적극적으로 해석할 것이다. 사정변경에 의한 취소신청이 기각되어 확정되었더라도, 새로운 사정변경이 있음을 이유로 새로운 취소신청을 할 수 있다.

그러나 소유권이전등기청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정의 집행 후 그 가처분의 피보전권리에 기한 소유권이전등기가 마쳐졌다면 그 가처분은 이미 그 목적을 달성한 것으로서, 이 경우 가처분등기의 말소는 그 말소에 관하여 이익을 갖는 자가 집행법원에 가처분의 목적달성을 이유로 하여 신청할 수 있으며, 그 신청에 기하여 집행법원은 별도의 취소결정 없이 등기관에게 말소의 촉탁을 하여야 하고(2011. 4. 12. 법률 제10580호로 개정된 부동산등기법은 종전과 달리 같은 법 94조 2항에 따라 해당 가처분등기는 등기관이 직권으로 말소하도록 하였다), 당해 가처분등기에 대한 말소촉탁의 신청 시에는 가처분권리자나 채무자로 하여금 별도의 가처분취소신청이나 가처분집행취소신청을 하
 194 할 필요가 없으므로, 이와 같이 가처분의 목적이 달성된 후에 사정변경이 있음을 주장하여 그 가처분결정 자체의 취소를 신청하는 것은 아무런 이익이 없어 부적법하다(대판 2004. 10. 15. 2004다34738, 대판 2005. 5. 27. 2005다14779).

(3) 신청방법과 접수

신청의 방법과 첨부인지 등은 이의신청사건의 경우와 같다. 보전처분취소신청서는 소장의 구실을 하므로 취소신청은 반드시 서면으로 하여야 하고, 그 신청서에는 보전처분의 취소를 구한다는 신청의 취지와 이유 및 사실상의 주장을 소명하기 위한 증거 방법을 적어야 한다(민집규 203조 2항).

접수의 방법도 이의신청사건과 같으나 크게 다른 점은 그 기록의 조제방법이다. 즉 취소사건은 보전처분기록과는 별도의 기록으로 조제하여야 한다. 표지의 사건번호란에는 취소사건의 번호를 기재하며 관련사건란에 보전처분 사건번호를 기재하고 신청인란에는 채무자를, 피신청인란에는 채권자를 기입한다(이 경우 괄호 속에 채무자, 채권자를 표시함이 좋다). 이 기록은 보전처분기록에 첨부하며 보전처분기록표지의 관련사건란에 취소사건의 번호를 표시한다(재민 91-1).

(4) 신청의 취하

보전처분의 취소신청은 보전처분 발령 후에 발생한 사정에 기하여 행해지는 것이어서 사정이 변경되면 몇 회라도 신청이 가능하고 그 취하에 의해서 채권자가 불이익을 입을 염려도 없으므로 그 취하에 채권자의 동의가 불필요한 것은 이의신청취하의 경우와 다를 바 없다. 취하의 방식과 채권자에 대한 취하서 등의 송달절차는 이의신청취하의 경우와 같다.

(5) 취소신청과 집행정지

가처분에 대한 취소신청이 있는 경우에도, 그 목적이 가처분취소를 구하는 점에서는 가처분의신청과 동일하여 집행정지에 관하여도 양자를 달리 취급할 필요가 없으므로, 가처분취소에도 가처분의신청 시의 집행정지에 관한 규정이 준용된다(민집 310조). 195

제3편
제5장
제3절

라. 취소제도 상호 간의 관계

보전처분취소에 관한 규정이 규율하는 취소사유마다 심판대상이 다르므로 동시에 신청하는 것도 가능하지만, 동일한 취소사유에 해당하는 각각의 사실에 관하여는 별개의 신청을 동시에 할 수는 없다. 신청이 경합하는 경우 사건의 병합은 보전처분이의와 보전처분취소가 경합하는 경우와는 달리 허용되고, 처음부터 병합신청을 하는 것도 허용된다. 실무상으로는 주위적으로 사정변경에 의한 보전처분취소를 신청하고, 예비적으로 특별사정에 의한 보전처분취소를 신청하는 사례가 많다. 특별사정에 의한 취소신청을 사정변경에 의한 취소신청으로 변경하는 것도 가능하다. 이와 달리 보전처분취소절차에서는 법률에 규정된 취소사유 이외의 보전처분이의사유를 주장할 수 없다.

마. 심리와 재판

(1) 심리

2005. 1. 27. 개정된 민사집행법은 재판의 형식에 관하여 모두 결정으로 하도록 통일하였다(민집 287조 3항, 288조 3항, 307조 2항, 286조 3항). 심리의 방식에 관해서는 제소기간 경과로 인한 보전처분취소절차의 경우에는 종전과 같은 방식을 유지하였기 때문에 서면심리만으로도 가능하지만, 나머지 취소절차에서는 반드시 임의적 변론기일 또는 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일을 열도록 규정하였다(민집 288조 3항, 307조 2항,

286조 1항). 이의신청절차에서 결정이유의 인용(민집규 203조의3 2항), 심리종결선언, 결정이유의 필수적 기재, 결정의 효력유예선언(민집 288조 3항, 301조, 307조, 286조 2, 4, 6항)과 기일통지에 관한 내용은 민사집행법 288조 1항의 각 보전처분취소신청 및 307조의 특별사정으로 인한 가처분취소신청절차에서도 그대로 적용된다.

196 (2) 재판

본안에 대한 심리가 끝나면 법원은 취소신청을 인용하여 보전처분을 취소하거나 취소신청을 각하 또는 기각한다. 취소신청 중 일부만 인용되면 보전처분을 일부취소하고 나머지 취소신청은 기각한다. 취소사건의 재판에는 취소사건의 사건번호를 쓴다. 취소신청을 인용하는 경우의 주문례는 다음과 같다.

1. 위 당사자 사이의 ○○법원 20○○카단○○○ 가처분신청사건에 관하여 위 법원이 20 . . .에 한 가처분결정을 취소한다.
2. 소송비용은 피신청인이 부담한다.

신청을 기각하는 경우 주문례는 다음과 같다.

1. 신청인의 신청을 기각한다.
2. 소송비용은 신청인이 부담한다.

2. 제소기간 경과로 인한 취소

가. 의의

보전처분은 본안에서 얻고자 하는 집행권원의 집행을 보전함에 그 목적이 있는 것이므로 본안의 소가 제기될 것이 당연히 예상되나, 일단 보전처분이 발령되면 채권자는 구태여 본안의 소를 제기할 필요를 느끼지 않고 권리의 보전만으로 만족하여 채무자의 자진이행을 기다리는 경우가 많기 때문에 채무자로 하여금 채권자가 본안의 소를 제기할 때까지 일방적으로 보전처분으로 인한 불이익을 수인하게 하여야 한다면 불합리하게 된다. 그러므로 채무자에게 채권자로 하여금 상당한 기간 내에 본안의 소를 제기하고 이를 증명하는 서류를 제출할 것을 명하도록 법원에 신청할 권리를 주고, 채권자가 이 명령을 이행하지 않으면 피보전권리를 조속히 실현할 의사가 없다고 보아 채무자의 신청에 의하여 보전처분을 취소하도록 한 것이 이 제도이다(민집 287조, 301조).

나. 본안의 제소명령

197

(1) 제소명령의 신청

(가) 관할법원

제소명령을 발령할 수 있는 법원은 보전처분을 발령한 법원이고, 이는 전속관할이다(민집 287조 1항, 301조). 항고법원이 스스로 보전처분을 발령한 경우에 제소명령을 발령할 수 있는 법원은 항고법원이 된다.

(나) 신청인

제소명령의 신청인은 채무자, 일반승계인, 파산관재인(대결 2008. 1. 17. 2007마519) 등이고, 채무자의 일반채권자, 가압류목적물의 양수인, 가처분목적물의 승계인 등 제3자도 채권자대위의 요건을 만족하면 신청인이 될 수 있다.

가압류결정이나 가처분결정에 대한 이의신청은 그 결정에 대한 소송법상의 불복방법으로서, 이미 개시된 가압류·가처분의 소송절차에서 그 소송을 수행하기 위한 절차상의 권리에 지나지 않는 것이므로, 그 소송절차의 주체인 소송당사자만이 그 권리를 행사할 수 있지만, 가압류·가처분결정에 대한 본안의 제소명령을 신청할 수 있는 권리나 제소기간의 도과에 의한 가압류·가처분의 취소를 신청할 수 있는 권리는 가압류·가처분신청에 기한 소송을 수행하기 위한 소송절차상의 개개의 권리가 아니라 가압류·가처분신청에 기한 소송절차와는 별개의 독립된 소송절차를 개시하게 하는 권리라고 할 것이므로, 이는 채권자대위권의 목적이 될 수 있다(대결 2011. 9. 21. 2011마1258).

그러나 소유권이전등기청구권에 대한 처분금지가처분의 제3채무자는 가처분에 대한 제소명령의 신청권이 없으므로 제3채무자가 채권자를 상대로 한 제소명령신청은 부적법하다(대결 1993. 10. 15. 93마1435).

채권자가 다수의 채무자를 상대로 보전처분신청을 하여 다수의 채무자들에게 보전처분이 발령된 사안에서 채무자들 중 일부만이 제소명령을 신청한 경우, 신청인은 제소명령을 신청한 그 채무자들에 한정되고, 다른 채무자들이 별도로 제소명령을 신청한 경우에는 사건번호를 별도로 부여하고 제소명령도 별도로 송달한다. 보전처분신청절차에서 이루어진 선정행위의 효력은 그에 기한 제소명령신청 사건에는 미치나, 보전처분취소신청 사건에서는 그 선정의 효력이 미치지 않는다(대판 2001. 4. 10. 99다49170). 보전처분신청을 대리한 소송대리인이 있는 경우에는 그 위임의 효력이 제소명령신청사건에도 미친다(대결 2003. 8. 22. 2003마1209).

(다) 신청의 요건

보전처분이 발령되어 유효하게 존속함에도 불구하고 채권자가 본안의 소를 제기하지 않는 이상 채무자는 보전처분의 발령법원에 본안의 제소명령을 신청할 수 있다. 따라서 이의사건에서 보전처분을 인가하는 결정이 확정된 후에도 신청할 수 있다. 보전집행이 이루어졌는지 여부와 관계없으므로, 집행기간을 경과한 경우나 해방금의 공탁에 의하여 집행이 취소된 경우에도 신청할 수 있다.

(라) 신청의 방식

신청은 신청취지와 이유를 적은 서면으로 하여야 하며(민집규 203조 1항 4호, 2항), 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항 4호). 채무자는 보전처분이 발령된 사실을 소명하여야 하나, 본안의 소가 아직 제소되지 아니한 사실은 주장만 하면 되고 증명까지 할 필요는 없다. 신청이 접수되면 신청사건부에 등재하고 기록은 보전처분사건 기록에 합철한다(재민 91-1).

(마) 신청의 취하

채무자는 제소명령을 발령하기 전에 제소명령신청을 취하할 수 있고, 이 경우 채권자의 동의는 필요 없다(민집 290조 2항, 287조 1항, 285조).

(2) 제소명령

(가) 제소명령의 발령

제소명령은 변론 없이 결정의 형식으로 한다(민집 287조 1항). 실무상 제소명령은 사법보좌관이 주로 발령하고 있다(사보규 2조 1항 15호). 법원은 신청의 적법 여부만 심리하면 족하고 추가로 사실관계를 조사할 필요가 없다. 제소명령에서는 채권자에게 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하거나 이미 소를 제기하였으면 소송계속사실을 증명하는 서류를 제출할 것을 명하고 그 기간(제소기간)을 정하면 된다. 제소할 법원이나 본안의 소의 내용까지 정하지는 않는다. 제소기간을 정하지 아니한 제소명령은 아무런 효력이 생길 수 없고, 따라서 이러한 재판의 정본이 송달되어도 소제기기간 경과에 의한 취소권은 생기지 않는다.

제소기간은 2주일 이상으로 정하여야 한다(민집 287조 2항). 종래의 실무에서는 제소기간을 7일로 정하는 것이 일반적이었으나, 민사집행법에서는 기간 내에 소제기뿐 아니라 소제기 사실을 증명하는 서류를 제출할 것을 요구하고 있으므로 제소기간이 지나치게 짧아 사실상 제소가 봉쇄된 채 보전처분이 취소되는 사태를 방지하기 위한 것이다. 지정된 기간이 만료된 이후에도 이를 늘리는 결정을 할 수 없다.

예규(재일 2003-7)가 정하는 제소명령의 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A4761] 제소명령

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건 20 카소	제소명령
채권자	
채무자	
주 문	
채권자는 이 결정을 <u>송달받은 날부터 ○○일 안에 ○○법원 20 카단 가압류사건에 관하여 본안의 소를 제기하고 이를 증명하는 서류를 제출하거나 이미 소를 제기하였으면 소송계속사실을 증명하는 서류를 제출하라.</u>	
이 유	
주문 기재 가압류사건에 관한 채무자의 제소명령 신청은 <u>이유 있으므로</u> 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판사(사법보좌관)	㉠
◇ 유의사항 ◇	
1. 채권자가 위 기간 안에 위 서류를 제출하지 아니한 때에는 법원은 채무자의 신청에 따라 가압류·가처분을 취소하게 됩니다(민사집행법 제287조 제3항, 제301조). 2. 채권자가 위 서류를 제출한 뒤에도 본안의 소가 취하되거나 각하된 경우에는 그 서류를 제출하지 아니한 것으로 보게 됩니다(민사집행법 제287조 제4항, 제301조).	

민집 287①

(나) 제소명령의 고지

200

제소명령신청을 인용하는 경우에는 채권자와 채무자에게 고지하고, 이를 배척하는 경우에는 채무자에게만 고지한다(민집규 7조 2항). 채권자에게 제소명령을 고지할 때는 송달의 방법에 의하여야 한다(민집규 206조 1항). 만일 보전처분신청을 대리한 소송대리인이 있는 경우에는 그 위임의 효력이 제소명령 신청사건에도 미치므로 제소명령의 송달을 그에 대하여 할 수 있다(대결 2003. 8. 22. 2003마1209). 한편 주소 등이 바뀐 경우의 신고 의무를 규정하고 있는 민사집행법 14조는 집행절차에 관하여 적용되는 규정이어서 집행에 관한 절차가 아닌 제소명령절차에 관하여 적용될 여지가 없고, 채권자가 송달장소로 신고한 장소에 송달된 적이 없다면 그곳을 민사소송법 185조에 규정된 ‘종전에 송달받던 장소’라고 볼 수 없다(대결 2005. 8. 2. 2005마201, 대결 2005. 12. 20. 2005마1022).

제소명령의 공시송달도 가능하다.

(다) 재판에 대한 불복

제소명령신청을 기각 또는 각하하는 결정에 대하여는 통상항고로써 불복할 수 있음은 물론이다(민소 439조). 제소기간을 너무 장기간으로 정한 제소명령은 실질적으로 신청을 기각한 것과 다름이 없으므로 이에 대하여도 불복할 수 있다.

반면에 제소명령이 발령된 경우에 그 제소명령은 민사소송법에서 일반적으로 항고의 대상으로 삼고 있는 같은 법 439조 소정의 '소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령'에 해당하지 아니하고, 또 이에 대하여 불복할 수 있음을 정하는 별도의 규정도 없으므로, 채권자는 그 명령에 대하여는 이의신청이나 항고를 할 수 없다. 채권자는 제소명령이 부당하더라도 제소명령 불이행을 이유로 한 보전처분 취소절차에서 제소명령의 당부에 관하여 다툴 수 있고 제소명령이 정당하다고 하여 보전처분이 취소되면 그 취소결정에 대하여 즉시항고로 다툴 수 있으므로, 제소명령은 같은 법 449조에서 특별항고의 대상으로 정하고 있는 '불복할 수 없는 명령'에도 해당되지 않는다(대결 2013. 3. 8. 2013그53).

201 다. 제소기간 경과로 인한 취소

(1) 취소신청

채권자가 법원이 정한 제소기간 내에 제소증명서 등을 제출하지 않으면 채무자는 보전처분의 취소를 신청할 수 있다. 제소명령의 신청이 취소의 신청까지를 포함하는 것은 아니므로 별도로 신청하여야 한다. 취소신청은 신청의 취지와 이유 및 사실상의 주장을 소명하기 위한 증거 방법을 적은 서면으로 하여야 한다(민집규 203조). 취소신청은 보전처분이 취소되기 전까지 제기할 수 있다.

(2) 제출기간 내에 제소증명서 등의 미제출

(가) 채권자의 증명책임

채권자는 본안의 소가 제기되었다는 사실을 증명하여야 한다. 소를 제기하면 족하고 소장 부분이 상대방에게 송달될 필요는 없다. 채권자는 지정된 기간 내에 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하거나 이미 소를 제기하였으면 소송계속사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다(민집 287조 1항).

이와 같은 증명서류는 일종의 법정증거에 해당하므로, 증명서류 이외의 방법에 의한 소제기·소송계속의 증명은 허용되지 않는다. 제소증명서는 제소명령의 고지 후에 정해진 기간

내에 소를 제기한 취지의 증명만으로 충분하지만, 소송계속증명원은 제소명령의 고지 후에 지정된 기간 중에 소송이 계속하고 있다는 사실을 증명하는 것이어야 한다. 소접수증명원을 다른 가처분신청사건의 소명자료로 제출한 것만으로는 소제기증명원이나 소송계속을 증명하는 서면을 제출한 것으로 볼 수 없다(대결 2008. 2. 4. 2007스84). 채권자가 이미 집행권을 가지고 있는 경우에는 소명자료로 집행권원의 정본 또는 등본을 제출하면 충분하다.

(나) 소가 취하·각하된 경우

소제기를 증명하는 서류를 제출한 뒤에 본안의 소가 취하되거나 각하된 경우에는 그 서류를 제출하지 아니한 것으로 본다(민집 287조 4항). 제소기간의 경과 여부를 판단할 때 제소명령에 응하여 채권자가 제기한 본안의 소송이나 중재절차가 취하되거나 당사자의 불출석으로 인하여 취하간주 또는 종료선언되거나 소송요건의 흠결을 이유로 한 소각하 판결이 확정되었을 때에는 본안의 소제기나 중재신청을 하지 아니한 것과 같이 보아야 한다(대판 2000. 2. 11. 99다50064). 또한 제소명령에 응하여 제기한 본안의 소를 각하한 판결이나 중재절차를 종료한 선언이 확정되면 그 절차에 위법이 있다 하더라도 제소기간의 경과 여부를 판단함에는 아무런 영향도 미칠 수 없다(대판 2000. 2. 11. 99다50064).

(다) 일부 채권액만 본안 소송을 제기한 경우의 효력

가압류의 피보전채권 중 일부 채권액에 대해서만 정하여진 기간 이내에 본안의 소를 제기하고 나머지 채권액에 대하여는 그 기간이 지난 뒤에 청구취지 확장의 방법으로 본안의 소를 추가로 제기한 경우에는 일부 채권액에 대하여만 정하여진 기간 이내에 본안의 소를 제기한 것에 불과하므로 나머지 채권액에 대하여는 가압류명령을 취소하여야 한다. 가령 피보전채권액이 15억 원임에도 제소명령을 송달받고도 1억 원의 지급을 구하는 본안의 소를 제기하였다면 1억 원의 청구액을 초과하는 피보전채권 부분에 대한 가압류결정은 제소명령에 반하는 것으로 취소되어야 하고, 그 후 제소명령에서 정한 제소기간이 지난 이후에 가압류취소결정에 불복하여 항고를 제기하면서 비로소 본안의 소의 청구 취지를 15억 원으로 확장하는 청구취지확장신청서를 제출하였더라도 위 청구취지의 확장 부분에 대해서는 제소명령을 이행하지 아니한 것으로 보아야 한다(대결 2008. 7. 10. 2008마260).

(라) 제출기간의 준수 의무

지정된 기간 이내에 본안의 소가 제기되었거나 이미 소를 제기하여 계속되고 있었음에도 불구하고 채권자가 그러한 사실을 증명하는 서류를 기간 이내에 법원에 제출하지 아니한 경우에도 법원은 보전처분을 취소하여야 하고, 그 기간이 지난 뒤에 증명서류를 제출하였다고 하더라도 마찬가지이다(대결 2003. 6. 18. 2003마793). 채권자가 정해진 기간

- 203 내에 본안의 소를 제기하고 소제기증명서를 제출하였으나 그 기간이 지난 뒤에 청구기초의 동일성이 인정되는 별소를 제기하고 원래의 소를 취하한 경우에도 보전처분을 취소하여야 한다(대결 2008. 7. 10. 2008마332).

제출기간을 지키지 못한 데에 채권자에게 잘못이 없는 경우에도 반드시 보전처분을 취소하여야 하는가가 문제되는데, 천재지변이나 이와 유사한 부득이한 사유가 있어 법원이 명한 기간 내에 민사집행법 287조 1항의 서류를 제출하지 못하였다거나, 채무자가 제소명령신청권을 남용하였다는 등의 특별한 사정이 있고 취소신청의 심리 종결 전에 제소증명서 등이 제출된 극히 예외적인 경우에 한하여 그 취소를 면할 수 있다(대결 2003. 6. 18. 2003마793, 대결 2005. 5. 9. 2005마310).

(3) 본안의 소의 의미

(가) 심리대상의 동일성

본안소송의 소송물은 보전소송의 피보전권리와 청구의 기초가 동일하면 족하다(대판 1982. 3. 9. 81다1221, 1222, 대판 2001. 3. 13. 99다11328).

(나) 소의 종류

통상 소의 제기 이외에도 반소의 제기, 독립당사자참가, 공동소송참가 등도 본안의 소제기에 해당한다. 소의 종류에 관하여는 본집행을 위하여 집행권원을 형성하는 이행소송에 국한된다는 견해도 있으나 피보전권리를 확정할 수 있는 경우이면 족하므로, 장래이행의 소, 확인의 소, 형성의 소도 가능하다. 승계집행문부여신청이나 집행문부여의 소도 본안의 소에 준한다고 해석하는 견해도 있으나, 이와 같은 집행적격의 문제에서 피보전권리의 존부를 확정하는 방법은 없으므로 소극적으로 해석하는 것이 타당하다.

(다) 본안의 소에 준하는 경우

- 본안의 소는 반드시 판결을 목적으로 하는 일반의 소제기만을 의미하는 것은 아니고 그 외에 조정, 지급명령, 제소전화해, 중재(대판 2000. 2. 11. 99다50064), 소송비용액확정신청(소송비용상환청구권을 피보전권리로 하여 가압류를 한 경우), 부동산인도명령의 신청 등도 포함된다. 그러나 채권자에 의한 회생절차개시신청(채무자회생 34조 2항), 파산신청(채무자회생 294조)은 신청원인의 존부를 판단하여 회생절차를 개시하거나 파산선고를 구하는 절차개시의 신청에 그치고, 회생채권·파산채권을 확정하기 위해서는 별도의 절차를 거쳐야 하므로 피보전권리를 종국적으로 확정할 수 있는 절차에 해당한다고 볼 수 없으므로 본안의 소에 해당하지 않는다.
- 204

채권자가 이미 집행권원을 갖고 있는 경우는 소제기가 있었던 경우와 동일하게 볼 수 있다. 이러한 집행권원에는 확정판결 이외에 조정조서·화해조서도 포함된다. 다만 이러한 경우에는 그 집행권원을 제소기간 내에 제출하여야 할 것이다.

공정증서도 집행권원에 해당하지만(민집 56조 4호, 공증인법 56조의2 4항), 집행력만 있을 뿐 확정판결과 동일한 효력이 없고, 공정증서작성절차는 본안소송과 직접 관련이 없으므로, 공정증서작성의 촉탁은 피보전권리를 중국적으로 확정할 수 있는 절차에 해당한다고 볼 수 없다는 견해도 있지만, 집행력 있는 공정증서상의 금전채권을 피보전권리로 하여 가압류를 신청할 수 있음에도 공정증서의 작성을 본안의 소로 보지 아니하면 채권자는 집행권원을 갖고 있음에도 다시 소를 제기하여야 한다는 결론에 도달하게 되어 소송경제에도 반한다. 따라서 공정증서작성절차도 본안의 소제기에 준한다고 보는 것이 타당하다. 실무 또한 공정증서는 제소명령에서 정하는 본안의 소에 준하는 것이라고 봄이 타당하고, 채권자가 제소명령에서 정한 기간 내에 법원에 공정증서 사본을 제출하면 제소명령에 따른 본안 제소를 한 것으로 보고 있다(서울중앙지결 2015. 5. 1. 2015카단20146, 서울중앙지결 2013. 6. 3. 2013카단20103).

(라) 외국법원에 소를 제기한 경우

민사소송법 및 민사집행법이 제소명령에 따른 본안의 소를 제기할 법원의 범위를 규정하고 있지 않으므로, 본안의 소를 제기할 법원에 외국법원이 포함되는지 여부는 법률해석의 문제에 속한다. 채권자가 보전처분의 본안의 소를 외국법원에 제기하는 경우에도 피보전권리를 실현할 의사를 상당한 정도로 객관적이고 실효적인 방법에 의하여 표명하였다고 볼 수 있는 점, 확정된 외국판결은 국내에서 그 효력이 인정될 수 있고 집행판결에 기한 강제집행도 가능하며, 국내에서 미리 한 보전처분과도 연계될 수 있으므로, 보전처분 후 채권자의 해태로 인한 채무자의 불이익이나 불안도 채권자의 외국법원에 대한 제소에 기하여 향후 실제로 해소될 것이 예상된다는 점 등을 종합하여 보면, 외국법원도 제소명령에 따른 본안의 소를 제기할 법원에 포함된다고 해석함이 타당하다. 다만 외국법원에 제기된 본안의 소에 대하여 그 본안소송의 적격성 인정 여부를 판단할 때 외국판결의 승인 내지 집행요건의 구비 또는 구비가가능성 여부를 조건으로 하여야 할지에 대하여는 조건으로 해석할 필요가 없다는 견해와 국내에서 승인을 얻을 수 있는 경우에 한하여 본안소송의 적격성을 긍정하는 견해가 대립하고 있다.

(마) 채권양도의 경우 채권양수인이 본안 제기 가능

제소명령 후 가압류결정의 청구채권을 양도한 경우에는 채권양도의 대항요건을 갖추지

못하였더라도 채권양수인이 채권양도인의 제소명령상의 지위를 승계하고, 제소명령에서 정한 기간 내에 채권양수인이 본안의 소를 제기하고 소장접수증명서를 첨부한 제소신고서를 제출한 이상 제소명령을 준수하였다고 봄이 타당하다(대결 2014. 10. 10. 2014마1284).

(4) 심리와 재판

(가) 심리

취소신청에 대하여는 임의적 변론이나 심문 또는 서면심리를 거친다. 실무상으로는 서면심리만으로 심리를 진행하는 것이 일반적이다. 제소기간 경과로 인한 취소절차에서도 채무자가 원고의 지위에 서게 되는 것이지만 그 쟁점의 성격상 채무자는 제소기간 내에 제소증명서 등이 제출되지 않았음을 주장하기만 하면 족하고, 채권자가 오히려 제소증명서 등이 기간 내에 제출되었음을 증명하여야 한다.

206 제소기간 경과로 인한 보전처분취소절차에서는 제소기간 경과 여부 외에도 제소기간의 상당성 여부, 제소기간 경과의 원인, 본안소송의 소송물과 피보전권리의 동일성 여부, 본안의 적격성 등도 함께 심리하게 된다. 보전처분이 적법하게 발령되었는지 여부나 본안의 소가 승소가능성이 있는지의 여부는 심사의 대상이 아니다.

(나) 재판

취소신청에 대하여는 결정으로 재판한다(민집 287조 3항).

13필지의 토지를 대상으로 하는 처분금지가처분결정에 대한 제소명령이 그중 어느 부분에 대한 것인지 특정되지 아니하였더라도, 채무자가 그 중 2필지의 토지에 대해서만 제소명령 불응을 이유로 한 가처분취소를 신청하였다면 위 제소명령은 그 2필지의 토지에 대해서만 효력이 있다(대결 2008. 5. 9. 2007마696). 제소기간 경과로 인한 보전처분취소의 경우에는 효력유예선언에 관한 규정(민집 286조 6항)이 준용되지 아니하므로, 법원은 효력유예선언을 할 수 없다.

(다) 불복절차

제소기간 경과로 인한 보전처분취소신청에 관한 결정에 대하여는 쌍방 당사자가 즉시항고로 불복할 수 있다. 다만 이 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없다(민집 287조 5항). 제소명령 불이행을 이유로 한 보전처분취소결정은 민사집행법 15조의 '집행정지에 관한 집행법원의 재판'에 해당한다고 볼 수 없으므로(대결 2005. 8. 2. 2005마201, 대결 2006. 5. 22. 2006마313), 그에 대한 즉시항고에 관해서는 민사집행법 15조가 아니라 민사소송법상 즉시항고에 관한 규정이 적용된다(대결 2006. 9. 28. 2006마829).

3. 사정변경에 따른 보전처분의 취소

가. 의의

보전처분의 발령 후 보전처분의 이유가 소멸되거나 그 밖에 사정이 바뀌어 보전처분을 유지함이 상당하지 않게 된 때에는 채무자는 보전처분의 취소를 구할 수 있다(민집 288조 1항 1호, 301조). 보전처분은 일정한 시점을 기준으로 하여 그 당시의 피보전권리나 보전의 필요성이 있는가를 판단하고 발령하는 것이므로, 시일의 경과로 그 사정이 변경되면 피보전권리가 소멸되거나 보전의 필요성이 없게 되는 경우가 많고, 그때까지도 보전처분을 유지하는 것은 채무자의 이익을 크게 침해하는 것이 되므로 그 이익 구제를 위하여 마련된 제도이다.

207

사정변경에 따른 보전처분취소의 재판은 보전처분을 명한 법원이 관할법원이 되나 본안이 이미 계속된 때에는 본안법원이 재판한다(민집 288조 2항).

한편 보전처분이 집행된 뒤에 채권자가 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때에는 그것을 이유로 채무자나 이해관계인이 보전처분의 취소신청을 할 수 있다(민집 288조 1항 3호).

나. 사정의 변경

보전처분을 취소할 사정은 그 발령 전의 것이든 그 후의 것이든 관계없다. 취소사건의 심리종결 시까지 발생한 사유면 족하다. 여기에는 보전처분 발령 후에 그 요건이 흠결되기에 이른 경우(사정의 객관적 변경)뿐만 아니라 발령 당시에 이미 존재하고 있는 요건의 흠을 채무자가 그 후에 알게 된 경우(사정의 주관적 변경)도 포함된다. 사정변경의 사유는 채권자 측에서 발생하였든 채무자 측에서 발생하였든 묻지 않는다.

사정의 변경은 피보전권리에 관한 것과 보전의 필요성에 관한 것으로 나누어 볼 수 있다.

(1) 피보전권리에 관한 것

(가) 피보전권리의 소멸·변경

피보전권리에 관한 것으로는 피보전권리의 전부 또는 일부의 소멸·변경이 있다. 따라서 가압류의 피보전권리가 변제(대판 1994. 8. 12. 93므1259), 변제공탁 등으로 소멸된 사실은 사정변경에 의한 취소사유가 된다. 다만 자기의 부담부분을 넘은 변제를 한 보증인은 채권자의 승계인으로서 가압류에 의한 보전의 이익을 자신을 위하여 주장할 수 있으므로 보조참가 등을 통하여 다른 공동보증인이 신청한 사정변경에 의한 가압류취소에 대하여

208

도 사정변경에 해당된다. 한편 가압류의 목적인 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 존재하지 않음이 밝혀진 경우, 이는 가압류결정이 결과적으로 채권보전의 실효를 거둘 수 없게 됨에 그칠 뿐 가압류결정을 취소할 사유는 되지 못한다는 것이 판례이다(대판 1979. 8. 21. 79다876, 대판 1999. 3. 23. 98다63100).

피보전권리의 양도 등으로 인하여 피보전권리의 주체가 변경된 경우에는 사정변경에 따른 보전처분 취소는 불가능하고, 피보전권리의 승계인이 취소절차에 참가하여 취소를 다룰 수는 있다.

(나) 채권자 패소의 본안판결이 확정된 경우

본안소송과의 관계에서 보면, 채권자가 본안소송이나 채무자가 제기한 피보전권리 부존재확인청구소송에서 실체법상의 이유로 패소확정된 때에는 사정변경의 사유가 된다(대판(전) 1963. 9. 12. 63다354, 대판 1973. 3. 20. 73다165 등). 채권자가 위 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기하더라도 위 사유에 영향을 미칠 수 없다(대판 1991. 1. 11. 90다8770 등). 그러나 재심의 소에 의하여 확정판결이 취소되었다면 그 재심의 본안판결의 내용을 심리하여 보전처분 후에 사정변경이 있었는가 여부를 판단하여야 한다(대판 1968. 5. 21. 68다504). 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권의 등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 침해금지가처분의 피보전권리가 소멸한 것이므로 사정변경에 따른 가처분 취소사유에 해당한다.

제1의 본안소송을 위하여 발령된 보전처분을 제2의 본안소송을 위하여 유용하는 것은 허용되지 아니하므로(대판 2004. 12. 24. 2004다53715), 제1소송에서 채권자가 패소확정되면 사정변경에 따른 취소를 인정할 수 있다(대판(전) 1963. 9. 12. 63다354, 대판 1966. 1. 25. 65다2201 등). 예를 들면 본안소송으로 연대채무의 이행을 구하였다가 채권자가 패소확정된 경우에는, 다시 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였고 그 청구의 기초가 동일하다 하더라도 보전처분의 유용은 허용되지 않는다.

- 209 채권자가 여러 개의 피보전권리를 주장하여 보전처분을 얻은 후 그중 일부의 권리만을 주장한 본안소송에서 패소확정된 경우에도 사정변경에 따른 취소를 인정할 수 있다(보전의 1회성의 문제). 예를 들면 채권자가 점유권에 기한 인도청구권과 소유권에 기한 인도청구권을 피보전권리로 하여 보전처분을 받았는데 소유권에 기한 인도청구권을 본안으로 한 소송에서 패소확정되었다면, 그 후 다시 점유권에 기한 인도청구소송이 계속 중이더라도 사정이 변경된 경우에 해당한다(대판 1973. 3. 20. 73다165 참조).

원고 패소가 기한미도래 또는 조건불성취를 이유로 한 때에는 아직 피보전권리가 부정

된 것이 아니기 때문에 반드시 사정변경이 되었다고 말할 수 없지만(대판 2003. 6. 24. 2003다18005), 기한도래 또는 조건성취를 전제로 한 보전처분인 때에는 그 점에서 사정변경이 발생한 것이다. 본안소송이 이송된 것만으로는 사정변경이라고 볼 수 없으며, 본안소송에서 소송법상의 이유로 각하판결을 받은 경우에는 일반적으로 사정변경이 있다고 할 수 없다(대판 1995. 8. 25. 94다42211, 대판 2004. 12. 24. 2004다53715).

(다) 본안판결이 확정되지 아니한 경우

문제는 채권자패소의 판결이 확정되지 아니한 경우인데, 판례는 패소 판결이 청구 자체에 관한 것으로 원고의 청구권이 부정되고 그 판결이 판결이유, 증거 등에 비추어 상소심에서 취소나 파기될 염려가 없다고 인정되면 사정변경이 있는 것으로 본다(대판 1962. 1. 18. 4294민상648, 대판 1977. 5. 10. 77다471 등). 본안소송에서 채권자의 패소 판결이 상소심에서 변경될 가능성이 있는지 여부는 사정변경을 이유로 한 보전처분취소사건의 심리종결 시를 기준으로 하여 그때까지 제출된 당사자의 주장과 증거방법을 기초로 판단하여야 한다(대결 2008. 11. 27. 2007마1470).

(2) 보전의 필요성에 관한 것

(가) 보전의 필요성의 소멸·변경

보전의 필요성의 소멸은 확실한 물적·인적·담보의 제공, 채무액의 공탁 등을 그 예로 210
들 수 있다. 추가담보제공을 조건으로 하여 보전처분을 인가하였으나 그 담보를 제공하지 아니한 때에는 통상적으로 보전집행의 취소사유에 해당하므로 집행취소절차를 거치면 되고, 사정변경에 의한 취소신청을 할 실익은 없다.

점유침탈을 이유로 한 점유물반환청구권을 피보전권리로 하여 점유이전금지가처분결정을 받은 채권자가 채무자를 상대로 본소로 제기한 점유회수의 청구와 본소청구 인용에 대비하여 채무자가 반소로 제기한 소유권에 기한 인도청구가 모두 인용되어 확정된 경우, 본소 확정판결에 기한 점유회수의 집행은 무의미한 점유상태의 변경을 반복하는 결과를 초래할 뿐 아무런 실익이 없으므로, 그 집행을 보전하기 위한 점유이전금지가처분결정은 이를 더 이상 유지할 필요가 없는 사정변경이 생겼다고 보아야 한다(대결 2013. 5. 31. 2013마198). 또한 법인 등 단체 대표자의 직무집행을 정지하는 가처분결정이 있는 후 직무집행이 정지된 대표자의 임기가 만료되고 새로 단체의 대표자가 선임되었다면, 특별한 사정이 없는 한 직무집행이 정지된 위 대표자가 단체의 대표자로서의 직무집행을 계속하여 위 단체에 회복하기 어려운 손해를 입힐 가능성은 없어졌으므로, 위 가처분결정은 이를

더 이상 유지할 필요가 없는 사정변경이 생겼다고 한다(대판 1995. 3. 10. 94다56708, 대판 1997. 9. 9. 97다12167 등). 이때 새로운 단체 대표자를 특별승계인으로 보아 그에게 가압류취소 신청적격을 부여한 하급심 결정례도 있다.

(나) 보전의사의 포기·상실

피보전권리에 관하여 본안에서 조정 또는 재판상 화해가 성립된 경우에는 채권자가 보전의 이익을 포기하였는가를 구체적으로 검토하여 이를 긍정할 수 있는 때에 한하여 사정변경이 있다고 볼 수 있다(대판 1955. 10. 6. 4288민상80). 채권자가 본안에서 패소 판결을 받고 항소심에서 소를 취하하여 재소금지 원칙의 적용을 받는 경우는 사정변경에 해당한다 (대판 1999. 3. 9. 98다12287). 반면에, 본안소송에서 소의 취하 또는 취하간주가 있다 하여도 재소금지에 해당하지 아니하는 이상 보전의사를 포기하였다고 볼 수 있는 경우가 211 아니면 그 자체만으로는 사정변경사유로 볼 수 없다(대판 1992. 6. 26. 92다9449, 대판 (전) 1998. 5. 21. 97다47637 등).

위와 같은 경우 이외에도 채권자가 보전의사를 포기 또는 상실하였다고 인정되는 때에는 사정변경으로 될 수 있다. 채권자가 본안소송에서 승소하고 집행권원을 얻어 즉시 본집행을 할 수 있는 요건을 갖추었음에도 불구하고 상당기간이 지나도록 그 집행을 하지 아니하고 있는 경우(대판 1990. 11. 23. 90다카25246, 대판 2008. 3. 27. 2006다24568 등), 가처분채권자가 본안소송에서 승소판결을 받은 그 집행채권이 정지조건부인 경우라 할지라도 그 조건이 매대잔대금의 지급과 같이 집행채권자의 의사에 따라 즉시 이행할 수 있는 반대의무의 이행임에도 정당한 이유 없이 그 반대의무의 이행을 게을리하고 집행에 착수하지 아니하고 있는 때(대판 1985. 4. 9. 84다카2331, 대판 2000. 11. 14. 2000다40773)에는 보전의 필요성이 소멸되어 사정변경이 있다고 보는 것이 판례이다.

당사자 사이에 부집행의 합의가 성립한 경우 보전의사를 포기한 것으로 인정할 수 있다. 보전처분의 집행기간을 경과한 경우에도 사정변경을 인정할 수 있다.

(3) 심리

사정변경에 의한 보전취소소송에서는 채무자가 사정변경에 해당하는 구체적인 사실을 주장·소명하여야 한다. 증명의 정도는 소명으로 족하다. 법원이 취소사유 중 어느 하나를 심리한 결과 그것이 인정된 때에는 다른 취소사유를 심리할 필요 없이 취소결정을 할 수 있다. 피보전권리 또는 보전의 필요가 소멸되었다고 판단되는 한 구태여 다른 취소사유를 더 심리할 이유가 없기 때문이다.

(4) 재판

보전취소신청이 부적법하면 취소신청을 각하하여야 한다. 가처분의 목적이 달성된 후에 사정변경이 있음을 주장하여 그 가처분결정 자체의 취소를 신청하는 것은 그 취소신청의 이익이 없어 부적법하다(대판 2005. 5. 27. 2005다14779). 가압류에서 본압류로 이전된 경우에도 보전취소 신청을 구할 이익이 없어서 그 신청은 부적법 각하되어야 하지만, 가압류에서 이행된 본압류가 경매절차를 개시하는 결정을 한 부동산에 대한 후행 압류이고, 배당요구의 종기 이후의 경매신청에 의한 것이라면 그 취소를 구할 이익이 있다(대결 2016. 3. 24. 2013마1412).

212

보전취소신청이 이유 있으면 보전처분을 취소한다. 가압류명령이 가분적이며 그 일부만에 대하여 사정변경이 있는 경우, 예를 들면 가압류명령의 피보전채권 중 일부가 소멸된 때, 목적물건에 대하여 채권자의 사용을 허용한 가처분에서 채권자에게 그 사용을 허용할 필요는 없어졌으나 아직 현상불변경을 조건으로 채무자에게 사용케 할 필요가 있는 때 등의 경우에는 보전처분의 일부를 취소하고 그 나머지 취소신청은 기각한다. 또한 채권자가 본안소송에서 일부 승소하였으나 채무자가 보전처분 전부의 취소를 신청한 경우, 채권자가 패소한 부분에 한하여 보전처분을 취소하고 나머지 신청을 기각한다. 이와 같은 일부 취소의 경우 절차가 번거로워지므로 실무상으로는 채권자에게 패소한 부분에 해당하는 보전처분신청을 취하하도록 권유하고 있다. 한편 법원은 채권자에게 추가로 담보제공을 명하고 보전취소신청을 기각할 수도 있고, 채무자의 담보제공을 조건으로 보전처분을 취소할 수도 있다.

취소되는 사건의 재판에는 취소사건의 사건번호를 쓴다. 취소신청을 인용하는 경우의 주문은 통상 “위 당사자 사이의 ○○법원 20 카단○○○ 가처분신청사건에 관하여 위 법원이 20 . . . 별지 목록 기재 부동산에 관하여 한 가처분결정을 취소한다. 소송비용은 피신청인이 부담한다.”고 기재한다. 신청을 기각하는 경우에는 “신청인의 신청을 기각한다. 소송비용은 신청인이 부담한다.”라고 쓴다.

취소신청에 대한 결정에 대하여는 즉시항고로 불복할 수 있다(민집 288조 3항, 286조 7항). 취소결정에 대한 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없고(민집 288조 3항, 286조 7항 후문), 제한된 요건하에서만 당사자의 신청에 따라 재판의 효력을 정지시킬 수 있다(민집 289조).

213 다. 보전집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때

(1) 의의

민사집행법 288조 1항 3호의 “가압류가 집행된 뒤에 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때”라는 것도 채권자의 보전의사의 포기 또는 상실이 있는 경우의 한 예라고 볼 수 있다.

(2) 취지 및 개정 경위

채권자가 보전처분의 집행 후 3년 이상 본안소송을 제기하지 아니하면 채무자 또는 이해관계인의 신청에 따라 보전처분을 취소하도록 한 이 제도는 보전처분을 권리관계가 최종적으로 실현될 때까지 긴급하고 잠정적으로 권리를 보전하는 조치에 불과하므로, 채권자로 하여금 채권의 보전에만 머물러있지 말고 채권의 회수·만족이라는 절차까지 진행하여 법률관계를 신속히 마무리 짓도록 하고, 채권자가 이를 게을리한 경우에는 채무자가 보전처분으로 인한 제약으로부터 벗어날 수 있도록 하여 채무자의 재산권을 보호하고 미정리 등기부의 장기 방치를 방지하고자 하는 데 그 취지가 있었다.

구 민사소송법에서는 이 기간이 10년이었으나, 기간경과로 인한 보전처분취소제도에 독자적인 의의를 부여하고 보전처분의 장기화로 인한 채무자의 불편과 법원의 부담을 해소하기 위하여, 민사집행법 제정 시에는 취소를 구할 수 있는 기간을 보전집행 후 10년에서 5년으로 단축하였다가, 2005. 7. 28.부터 시행된 개정 민사집행법에서는 이를 3년으로 더욱 단축하였다.

민사집행규칙 부칙 3조는, “본법(2005. 1. 27. 법률 제7358호로 개정된 것) 시행 전부터 진행된 법정기간과 그 계산은 종전의 규정에 따른다”고 규정하고 있다. 따라서 ① 2002. 6. 30. 이전에 집행된 보전처분은 집행 후 10년이 경과하여야만 취소할 수 있고, ② 2002. 7. 1.부터 2005. 7. 27. 사이에 집행된 보전처분은 집행 후 5년이 경과하여야만 취소할 수 있으며, ③ 2005. 7. 28. 이후에 집행된 보전처분은 집행 후 3년이 경과하여야만 취소할 수 있다.

214 (3) 취소의 요건

보전집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 아니하면 그 후에 본안의 소를 제기하여도 가압류, 가처분의 취소를 배제하는 효력이 생기지 않는다(대판 1999. 10. 26. 99다 37887).

(4) 재판

채무자는 보전집행 후 3년이 경과한 사실에 관하여 주장·소명책임을 부담하지만, 보전집행 후 3년간 '본안의 소를 제기하지 아니하였다는 것'은 주장하면 족하고, 채권자가 본안의 소를 제기하였다는 것을 반대사실로 소명하여야 한다. 실무상으로는 취소신청에 대한 재판은 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문이나 임의적 변론을 거쳐야 하므로, 채무자의 위와 같은 주장이 기재된 신청서를 송달받고서도 채권자가 별다른 소명자료를 제출하지 아니하면 심리 전체의 취지로 채무자의 주장사실을 인정하여 보전처분취소결정을 하고 있다.

보전집행 후 3년간 본안의 소가 제기되지 아니하였다고 하여 보전취소결정 없이도 보전처분의 효력이 당연히 소멸되거나, 보전취소결정이 확정된 때에 보전집행 시로부터 3년이 경과된 시점에 소급하여 보전처분의 효력을 소멸하게 하는 것은 아니다(대판 2008. 2. 14. 2007다17222). 따라서 가처분의 피보전권리가 소멸되었음에도 불구하고 가처분이 취소되지 않고 있음을 이용하여 다른 동종의 권리로 그 가처분을 유용하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 가처분에 반하는 권리를 취득한 제3자는 가처분권자에게 대항할 수 없다(대판 2004. 4. 9. 2002다58389).

(5) 소멸시효중단효

3년간 본안의 소를 제기하지 아니하였음을 이유로 한 보전취소는 시효중단의 효력이 소급하여 없어지는 민법 175조에서 정한 보전취소의 경우에 해당하지 않는다(대판 2009. 5. 28. 2009다20).

4. 담보제공으로 인한 가압류취소 <→ 해방금 공탁에 의한 가압류집행취소

215

가. 의의

가압류는 금전채권의 집행보전을 목적으로 채무자의 일반재산을 확보하는 제도이므로 채무자가 적당한 담보를 제공한다면 구태여 일반재산을 가압류할 필요가 없게 된다. 채무자는 가압류결정상의 해방금액을 공탁하고 가압류집행의 취소·정지를 구할 수도 있으나 (민집 282조), 법원이 정한 담보를 제공하고서 그 가압류 자체의 취소를 구할 수도 있다 (민집 288조 1항 2호). 이 규정은 금전채권의 보전을 목적으로 하지 않는 가처분의 경우에는 성질상 준용되지 않으며(대판 1956. 5. 10. 4289민상26), 가처분에 대하여는 같은 취지에서 특별사정에 의한 취소의 절차가 따로 마련되어 있다.

담보제공으로 인한 가압류의 취소는 가압류의 피보전채권을 위하여 적당한 담보가 제공되었음을 이유로 하는 것이므로 사정변경으로 인한 취소의 일종이지만, 그 사정의 변경이 법원의 명령에 의한 담보제공으로 이루어졌다는 점에서 다른 경우와 구별된다.

나. 담보와 그 성질

(1) 담보제공으로 인한 가압류취소절차에서의 담보는 현금 또는 이에 상응하는 유가증권으로 제한되고 보증보험증권의 제출로는 갈음할 수 없는가. 충분한 담보력과 효용을 갖추고 있다면 이를 제한할 근거는 없으나 현재까지 이러한 보증서를 발급하는 금융기관이 없으므로 아직은 이용될 여지가 없다. 그 밖에 담보제공의 방법, 담보권의 실행 등에 관하여는 [I] 제1편 제7장 집행에 관한 담보·보증·공탁, 참조.

(2) 가압류해방금액이 가압류목적물을 대신하는 것으로 채권자는 그 공탁금 회수청구권을 가압류하는 것과 동일한 효과를 가질 뿐 여기에 대해 어떤 우선변제권을 갖는 것이
 216 아님에 대하여, 민사집행법 288조 1항 2호의 담보는 직접 피보전권리를 담보하는 것으로, 채권자는 여기에 대하여 일종의 질권을 갖게 된다(민집 19조, 민소 123조). 또 가압류취소로 인한 손해배상청구권만을 담보하는 이의사건에서의 취소결정 시에 제공하는 담보(민집 286조 5항)와도 구별된다.

(3) 채권자가 동일한 채권을 피보전권리로 하여 여러 건의 가압류결정을 받은 경우, 채무자가 각 가압류사건마다 청구금액 상당의 해방공탁을 하여야 가압류에서 해방되는 것은 불합리하므로, 법원이 청구금액 상당을 담보로 정하고 채무자가 그 담보를 제공하면 채권자가 이 담보에 질권을 갖게 되는 점을 고려하여 여러 건의 가압류결정을 모두 취소할 수 있다고 보는 것이 이 제도의 활성화를 위해서도 바람직하다.

다. 신청과 심리

신청인 적격, 신청의 시기와 방식, 관할법원은 앞의 총론에서 본 바와 같다. 다만 채무자는 단순히 적당한 담보를 제공하게 하고 가압류를 취소하여 달라는 신청을 하면 족하고 그 담보의 종류, 액수 등을 특정하여 표시할 필요는 없다.

법원은 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일이나 변론기일을 열어 적당한 담보의 종류와 액수를 결정하고 미리 담보제공을 명하고 그 이행을 기다려 가압류를 취소하는 결정을 하거나, 담보의 제공을 조건으로 가압류를 취소하는 결정을 한다. 담보는 법원이 자유재량으로 정할 수 있다. 가압류취소를 받기 위해 제공된 담보는 가압류명령 기재 청구

채권을 직접 담보하고 있으므로, 가압류채권자가 당해 가압류청구채권 중 일부에 관하여 본안의 소를 제기하였다고 하여 그 사실만으로 본안청구금액을 초과하는 부분에 대한 담보사유가 소멸하였다고 할 수 없다(대결 2008. 7. 1. 2008마711).

라. 하급심에서의 구체적인 활용사례

(1) 동일한 피보전채권을 근거로 중복가압류한 사례

동일한 피보전채권을 근거로 여러 건의 중복가압류 결정을 득한 경우, ① 여러 건의 중 217
복가압류 사건 전체에 대하여 동시에 담보제공 가압류취소신청을 하고, 그 신청에 대하여 1건의 피보전채권액 전액만을 현금담보로 제공하는 것을 조건으로 여러 건의 중복가압류 사건 전부의 취소를 명하거나(안산지결 2010. 3. 10. 2010카단864), ② 개별 중복가압류 사건별로 담보제공 가압류취소신청을 하고, 그 개별 신청에 대하여 피보전채권액을 안분한 돈을 현금담보로 제공하는 것을 조건으로 개별 가압류사건의 취소를 명한 하급심 사례(서울중앙지결 2017. 4. 26. 2017카단804696)가 있다.

다만 부진정 연대책임을 부담하는 다수 불법행위 채무자를 상대로 동일한 피보전채권을 토대로 여러 건의 중복가압류를 한 사례에서는 당사자들 가운데 현금담보를 제공하지 못하는 경우도 있을 수 있는 점, 담보제공을 조건으로 가압류 취소를 명하는 경우라 하더라도 피신청인 입장에서 가압류가 취소되지 않고 유지되는 경우보다 불리해지지 않는 금액을 담보로 제공하도록 하여야 하는 점 등을 고려하여 피보전채권액 전액을 안분한 돈만을 현금담보로 제공하게 하는 것은 부당하다는 이유로 피보전채권액을 불법행위자별로 안분한 돈의 약 2배에 해당하는 금액을 담보금액으로 정한 경우도 있다.

(2) 다른 중복가압류 사건에 대하여 전액을 해방공탁한 사례

다른 중복가압류 사건에 대한 해방공탁을 이유로 바로 보전의 필요성이 없다는 이유로 가압류이익을 받아들이는 사례도 있지만(인천지결 2017. 1. 31. 2016카단50291), 다수 결정례는 해방공탁금은 가압류의 목적재산에 갈음하는 것으로서 채권자는 채무자의 해방공탁금 회수청구권에 관하여 우선변제권이 없기 때문에 해방공탁으로 인하여 보전의 필요성이 부정될 만큼 채권자에게 충분한 물적 담보가 확보되었다고 보기는 어려운 점을 근거로 다른 중복가압류 사건에 대한 가압류이익이나 가압류취소신청을 기각하고 있다(인천지결 2017. 2. 17. 2016카단103545, 대구지결 2017. 2. 16. 2016카합296 등).

위와 같이 다른 중복가압류 사건에 대한 해방공탁이 된 경우에 보전의 필요성이 없다는

- 218 이유로 가압류이의 등을 받아들이기 어려운 경우에, 생각해 볼 수 있는 대안이 바로 다른 중복가압류 사건에서의 해방공탁금을 감안하여 피보전채권액보다 적은 현금을 담보제공 조건으로 한 가압류취소제도이고, 최근 하급심에서 이러한 제도를 활용한 사례가 늘고 있다(서울중앙지결 2017. 3. 2. 2016카단20444 등).

5. 특별사정에 의한 가처분취소

가. 의의

가처분은 금전채권의 집행을 목적으로 하는 것이 아니므로 채무자가 담보만을 제공한다 해서 곧 이를 취소하기에는 적당하지 않다. 그러나 가처분으로 인하여 채무자가 큰 손해를 입게 된다거나 또는 채권자의 피보전권리가 금전적 보상으로도 충족적 만족을 얻을 수 있다는 등의 특수한 사정이 있을 때에는 채무자의 피해를 경감하기 위하여 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소하는 것이 양 당사자의 이익교량상 필요하게 된다. 민사집행법은 가압류에서 담보를 제공하고 가압류를 취소할 수 있는 것과 궤를 같이하여 특수한 사정이 있는 가처분에서도 채무자로 하여금 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소할 수 있도록 하는 제도를 마련하였다(민집 307조). 이 취소제도는 다툼의 대상에 관한 가처분과 입시의 지위를 정하기 위한 가처분에 모두 적용된다.

민사집행법 307조는 같은 법 286조에 대한 특별규정이므로 가처분명령에 대하여 이의 신청이 있는 경우 법원이 특별사정을 인정할 수 있는 때에는 채무자가 담보를 제공하는 것을 조건으로 가처분명령의 취소·변경을 할 수 있다.

이 규정은 민사집행법 288조 1항 2호의 제도에 상응하는 가처분에서의 특별규정이며 같은 항의 사정변경과는 별개의 취소사유이다. 그러므로 사정변경이 인정되는 이상 담보의 제공이나 특별사정의 존재 등은 고려할 필요 없이 곧바로 민사집행법 301조, 288조 1항 1호에 의하여 가처분을 취소할 수 있다(대판 1966. 2. 28. 65다2560). 반대로 특별사정이 존재하고 담보제공이 있으면 사정변경이 없어도 가처분명령을 취소할 수 있다.

219 나. 특별사정

(1) 특별사정의 의의

특별사정이란 ① 가처분으로 보전되는 피보전권리가 금전적 보상에 의하여 충족적으로

만족을 얻을 수 있는 것이라는 사정, ② 채무자가 가처분에 의하여 통상 입는 손해보다 훨씬 큰 손해를 입게 될 사정을 말하며, 이 두 사정 중 어느 하나의 사정이라도 있으면 특별사정에 해당된다고 하는 것이 판례의 확립된 견해이다(대판 1992. 4. 14. 91다31210, 대판 1997. 3. 14. 96다21188 등). 다만 위 두 기준은 엄격히 구별되어 상호 배척하는 관계에 있는 것이 아니므로 채무자가 위 두 기준 중 어느 하나를 주장한 경우에도 법원은 그 주장에 구애됨이 없이 나머지 다른 사유로 취소할 수 있다.

(2) 금전보상의 가능성

금전보상이 가능한가의 여부는 장래 본안소송에서의 청구의 내용, 당해 가처분의 목적 등 모든 사정을 참작하여 사회통념에 따라 객관적으로 판단하여야 한다(대판 1997. 3. 14. 96다21188, 대결 2006. 7. 4. 2006마164). 예를 들면 공사잔대금 채권의 담보를 위한 유치권을 보전하기 위하여 발령된 출입금지등가처분(대판 1997. 3. 14. 96다21188), 사해 행위취소에 의한 소유권이전등기말소청구권을 피보전권리로 하여 발령된 처분금지가처분(대판 1998. 5. 15. 97다58316), 금전채권에 대한 처분금지가처분은 금전보상이 가능하다고 본다. 피보전권리가 담보물권(대판 1987. 1. 20. 86다카1547), 입목의 벌채를 목적으로 하는 토지인도청구권(대판 1966. 10. 18. 66다1748), 토지에 대한 소유권이나 점유방해배제청구권(대판 1967. 1. 24. 66다2127)인 가처분도 금전보상이 가능하다. 그 밖에 저장권 설정등기청구권, 소유권유보부매매계약의 해제에 의한 목적물인도청구권이나 양도담보권의 실행을 위한 담보물인도청구권을 피보전권리로 하는 점유이전금지가처분, 파산절차상의 부인권행사에 의한 목적물인도청구권을 피보전권리로 하는 점유이전금지가처분 등과 같이 그 종국적 목적이 금전적 가치의 파악에 있는 경우에는 위의 요건을 충족한다고 본다.

디자인권은 침해에 대한 손해액의 사정이 어렵고, 공업소유권의 침해에 의하여 공업소유권자의 명예·신용의 훼손에 의한 정신적 손해도 수반됨이 명백하므로, 피보전권리가 디자인권(대판 1981. 1. 13. 80다1334)인 경우에는 금전적 보상의 가능성이 적다고 보아야 한다. 공사금지가처분, 지식재산권침해금지가처분, 직무집행정지가처분, 인격권침해금지가처분이나 경영권 분쟁 상태에서의 주식의 처분금지가처분, 신주·사채발행금지가처분 등과 같이 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에서는 대부분의 경우에 금전보상의 가능성을 인정하기가 쉽지 않을 것이다. 한편 치료비나 임금의 임시지급을 명하는 가처분은 즉시 지급의 필요성이 있는 경우에 발령되는 것이므로, 장래 금전적 보상의 가능성이 있다고 하여 특별사정을 이유로 가처분을 취소하는 것은 허용되지 않는다.

(3) 채무자의 현저한 손해

채무자가 특히 현저한 손해를 입게 될 사정이 있는지 여부는 가처분의 종류, 내용 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 채무자가 입을 손해가 가처분 당시 예상된 것보다 훨씬 클 염려가 있어 가처분을 유지하는 것이 채무자에게 가혹하고 공평의 이념에 반하는지 여부에 의하여 결정할 것이며 위 채무자가 입을 손해는 반드시 공익적 손해임이 요구되는 것은 아니다(대판 1992. 4. 14. 91다31210, 대결 2011. 2. 14. 2010마1485).

유치권에 기한 출입금지가처분으로 인하여 공원묘원의 설치 운영을 목적으로 하여 설립된 재단법인인 채무자가 공원묘원에 출입조차 할 수 없게 되어 그의 유일한 재산인 공원묘원의 보존관리상태가 악화되고 사용권의 분양과 공원묘원의 관리 유지라는 목적사업에 중대한 지장을 받아 온 경우(대판 1997. 3. 14. 96다21188), 공사금지가처분 발령 후 채무자가 채권자에 대한 피해를 줄이기 위하여 지하굴착공법을 변경하였으며 공사가 금지된 당해 오피스텔이 50% 이상 분양된 경우(대판 1992. 4. 14. 91다31210)가 판례상 특별사정에 의한 가처분취소가 인정된 사례이다. 하급심에서도 채무자의 현저한 손해의 발생을
221 이유로 한 가처분취소를 인정한 사례가 많다.

다. 취소신청의 방법·시기·취하

취소신청은 서면으로 하여야 한다(민집규 203조 1항 5호). 신청서에는 신청의 이유를 기재하여야 하나 취소의 사유는 신청서에 기재된 것에 제한되지 않는다. 실기한 공격방어 방법이 아닌 한 심리종결 시까지 취소 사유를 주장·소명할 수 있다. 특별사정이 있는 때에 이를 이유로 하여 독립된 취소신청을 할 수 있는 외에, 다른 절차에서 취소신청을 하거나 혹은 이의절차에서 항변으로 이를 주장할 수 있는가의 문제가 있는데, 이를 허용하여도 무방하다.

특별사정에 의한 취소신청은 가처분에 의한 채무자의 불이익을 제거할 목적으로 가처분 자체를 취소시키려는 신청이므로 가처분의 효력이 발생한 후 존속 중이면 가능하다. 이의 소송에서 가처분을 인가하는 결정이 확정된 후에도 가능하다. 가처분의 집행 후는 물론 집행취소 후에도 가처분이 존속하는 한 신청할 수 있다.

특별사정에 의한 취소신청은 가처분 발령 후에 특별한 사정으로 인하여 행해지는 것이므로 그 취하에 의해서 채권자가 불이익을 입을 염려가 없다. 따라서 그 취하에 채권자의 동의가 불필요한 것은 이의신청취하의 경우와 다르지 않다. 취하의 방식과 채권자에 대한 취하서 등의 송달절차는 이의신청취하의 경우와 같다.

라. 심리와 재판

법원은 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일이나 변론기일을 열어 특별사정의 유무를 심리한다(민집 307조 2항, 286조 1항). 피보전권리의 존부나 보전의 필요성의 유무, 즉 가처분의 당부는 심리의 대상이 되지 아니하므로(다만 특별사정의 인정여부에 관한 하나의 자료에 불과하다), 이에 관하여는 심리 판단할 필요가 없고 오직 가처분취소사유인 특별사정의 유무를 심리판단하면 된다(대판 1987. 1. 20. 86다카1547).

222

법원은 특별사정의 유무를 심리한 후 그 사정이 인정되면 채무자가 제공할 담보의 종류와 금액을 정하여 미리 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소하는 재판을 하거나 담보제공을 조건으로 가처분을 취소하는 결정을 하며, 그 특별사정이 인정되지 않거나 담보를 제공하지 않으면 취소신청을 기각한다.

이때의 담보도 가압류취소절차의 담보와 같이 현금 또는 이에 상응하는 유가증권으로 제한되는 것이 아니라 충분한 담보력과 효용을 갖추고 있다면 보증보험증권의 제출로도 갈음할 수 있다.

이 담보는 가처분의 성질상 피보전권리 자체를 담보하는 것이 될 수 없고 가처분채권자가 본안소송에서 승소하였음에도 가처분의 취소로 말미암아 가처분 목적물이 존재하지 않게 됨으로써 입게 되는 손해를 담보하기 위한 것이므로, 가처분채권자는 가처분취소로 인하여 입은 손해배상청구소송의 승소판결을 얻은 후에 민사집행법 19조 3항, 민사소송법 123조에 의하여 그 담보에 대하여 질권자와 동일한 권리를 가지고 우선변제를 받을 수 있다(대판 1998. 5. 15. 97다58316, 대결 2010. 8. 24. 2010마459).

제6장 보전항고

제1절 즉시항고

1. 보전처분신청을 배척하는 결정에 대한 즉시항고

가. 채권자의 즉시항고

(1) 채권자는 보전처분신청을 기각하거나 각하하는 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(민집 281조 2항, 301조). 종래에는 보전처분신청을 각하 또는 기각하는 결정에 대한 불복방법에 관하여 별도의 규정이 없었으므로, 채권자는 항고의 이익이 있는 한 언제라도 통상항고로 불복할 수 있었다. 그러나 보전처분신청은 긴급한 필요가 있는 때에 하는 것이므로, 그 신청을 배척하는 재판에 대한 불복도 신속하게 이루어져야 하고, 장기간이 경과한 후에 불복한다면 신청의 기초가 되었던 사정이 변할 수도 있어 보전재판의 성질에 반하게 되므로, 보전소송의 특성에 부합시키고 사건의 조속한 확정을 통한 기록처리상의 편의를 도모하기 위하여, 민사집행법은 신청을 기각하거나 각하하는 결정에 대한 불복은 즉시항고에 의하도록 한 것이다.

(2) 무담보의 가압류결정을 구하는 신청에 대하여 법원이 일정한 액수의 담보를 제공하는 것을 조건으로 가압류를 명하는 경우 이는 실질적으로 가압류신청에 대한 일부기각의 재판과 같은 성격을 가지는 것이므로 채권자는 가압류신청의 일부기각의 경우와 마찬가지로 즉시항고로 불복할 수 있다. 담보조건부 가압류결정에서 정한 담보의 액수가 지나치게

224 많다는 것을 다투는 방법도 같다(대결 2000. 8. 28. 99그30 참조).

(3) 채권자는 보전처분신청을 배척하는 결정에 대한 즉시항고절차에서도 신청의 기초의 동일성이 인정되는 범위 내에서 신청취지를 확장하거나 변경할 수 있다.

(4) 보전처분신청을 배척하는 결정에 대하여 채무자는 즉시항고나 이의신청 등으로 불

복할 수 없다(대결 2008. 10. 24. 2007마1377).

나. 신청서각하명령에 대한 불복방법

보전처분신청서의 필수적 기재사항이 갖추어져 있지 않거나 인지를 붙이지 아니한 경우에 재판장은 채권자에게 상당한 기간을 정하여 그 흠을 보정하도록 명하고, 채권자가 그 흠을 보정하지 아니한 때에는 명령으로써 보전처분신청서를 각하하는데, 위와 같은 보전처분신청서 각하명령에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 254조 1, 2, 3항).

다. 심리와 재판

원심법원에 즉시항고장이 제출된 경우 원심법원이 항고에 정당한 이유가 있다고 인정하는 때에는 재도의 고안으로 그 재판을 경정할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 446조). 즉시항고를 인용하는 경우 주문례는 다음과 같다.

1. 이 법원이 채권자와 채무자 사이의 20○○카단○○ 부동산가압류사건에서 20 . . .에 한 결정을 취소한다.
2. 채무자 소유의 별지 기재 부동산을 가압류한다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 집행취소를 신청할 수 있다.
 청구채권의 내용 : 20 . . .자 대여금
 청구금액 : 50,000,000원

채권자의 즉시항고를 기각하거나 각하하는 재판은 채무자에게 고지할 필요가 없다(민집 281조 3항, 301조).

2. 보전처분에 대한 즉시항고는 불가

225

보전처분에 대하여 채무자는 보전처분이의를 신청할 수 있을 뿐이고, 보전처분이 항고법원에 의하여 행하여진 경우라 하더라도 이에 대하여 민사소송법 442조의 재항고나 민사소송법 444조의 즉시항고로는 다룰 수 없다(대결 1999. 4. 20. 99마865, 대결 2008. 12. 22. 2008마1752).

3. 보전처분이의·취소재판에 대한 즉시항고

가. 의의

보전처분이의·취소재판에 대하여는 즉시항고로 불복할 수 있는데(민집 286조 7항, 287조 5항, 288조 3항, 301조, 307조), 항고사건은 실질적으로 서로 대립하는 상대방이 소송에서 자기의 권리신장을 위하여 공격·방어할 수 있는 기회가 보장된 대심적 소송구조에 해당한다(대결 2010. 5. 25. 2010마181).

나. 항고기간과 항고의 방식

(1) 즉시항고기간은 민사집행법에 특별한 규정이 없으므로, 항고인은 재판을 고지받은 날부터 1주 이내에 원심법원에 항고를 제기하여야 한다(민집 23조 1항, 민소 444조, 445조). 그러나 법원이 즉시항고 제기기간을 잘못 고지하였다면, 설령 즉시항고가 법정기간을 경과하여 제기되었다고 하더라도 그것이 그 고지된 기간 내에 제기된 이상 적법한 항고로 봄이 상당하다(대결 2007. 3. 26. 2006마1331, 대결 2007. 7. 27. 2006마1131).

(2) 즉시항고는 서면으로 하여야 하고, 신청의 취지와 이유 및 사실상의 주장을 소명하기 위한 증거 방법을 적어야 한다(민집규 203조 2항). 다만 위 규정은 훈시규정에 불과하여 구체적인 취소·변경사유나 증거가 적혀 있지 아니하여도 그 신청이 부적법한 것은 아니다. 항고장에는 보전처분신청서에 붙인 인지액의 2배에 해당하는 인지를 붙여야 한다(인지 11조 1항).

(3) 보전처분이의·취소재판에 관한 절차는 집행에 관한 절차가 아니므로, 민사집행법 15조의 '집행절차에 관한 집행법원의 재판'에 해당하지 않고, 따라서 그에 대한 즉시항고에 관해서는 민사집행법 15조가 아니라 민사소송법상 즉시항고에 관한 규정이 적용된다(대결 2006. 9. 28. 2006마829). 민사소송법은 민사집행법 15조와 달리 항소이유서의 제출기한에 관한 규정을 두고 있지 아니하므로, 민사집행법 15조가 아니라 민사소송법의 즉시항고에 대한 규정이 준용되는 보전처분이의·취소신청에 대한 재판에 있어서는 항고인이 즉시항고이유서를 제출하지 아니하였다거나 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 대법원규칙이 정하는 바에 따라 항고이유를 적지 않았다는 이유로 즉시항고를 각하할 수는 없다(대결 2008. 2. 29. 2008마145). 항고법원의 심리범위는 항고이유에 의하여 제한되는 것이 아니므로, 항고법원은 항고인의 항고이유서 제출 여부와 관계없이 항고이유의 주장이 없더라도 그 불복신청의 한도 안에서 기록에 나타난 자료에 의하여 제1심 재

판의 당부를 심리·판단하여야 한다(대결 2008. 2. 28. 2007마274, 대결 2010. 3. 3. 2009마876).

다. 즉시항고의 효과

민사집행법은 보전처분이의·취소재판에 대한 즉시항고에 관하여 집행정지의 효력을 부여하고 있는 민사소송법 447조의 준용을 배제하고 있다(집행부정지의 원칙, 민집 286조 7항, 287조 5항, 288조 3항, 307조 2항). 따라서 채무자의 이의·취소신청에 따라 보전처분을 취소하는 결정이 발령되면 채무자는 즉시 보전집행의 취소신청을 할 수 있다. 집행취소 후 채무자가 목적물을 처분하거나 피압류물에 관한 배당절차에서 배당요구종기가 지난 경우에는 항고심에서 채권자가 승소하더라도 채권자는 보전목적 달성을 수 없게 된다.

라. 보전처분취소결정의 효력정지

227

(1) 취지

채권자가 항고심에서 승소하더라도 집행부정지의 원칙상 위와 같이 보전목적 달성을 수 없는 경우도 있을 수 있다. 이에 따라 민사집행법 289조, 301조는 채권자의 보호를 위하여 보전처분취소결정의 효력유예제도와는 별도로 취소결정의 효력정지제도를 규정하였다.

(2) 요건

(가) 보전처분취소결정에 대하여 채권자의 즉시항고가 제기된 경우, 불복의 이유로 주장한 사유가 법률상 정당한 이유가 있다고 인정되고 사실에 대한 소명이 있으며, 그 보전처분을 취소함으로써 인하여 채권자에게 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 사정에 대한 소명이 있는 때에는 법원은 당사자의 신청에 따라 보전처분취소결정의 효력을 정지시킬 수 있다(민집 289조 1항, 301조). 보전처분취소결정은 당사자 쌍방의 주장·입증을 거쳐 실질적 심리가 이루어지고 그 결과에 기초하여 판단한 것이므로, 그 효력정지를 쉽게 인정하는 것은 보전처분취소결정의 효력을 즉시 생기게 하여 채무자를 가능한 한 빨리 보전처분으로부터 해방시키려는 개정법의 취지에 반하기 때문에, 이와 같이 효력정지의 요건을 엄격하게 규정한 것이다.

(나) 효력정지재판은 보전처분취소결정에 대한 즉시항고가 제기된 이후에 할 수 있다.

(다) 불복의 이유로 주장한 사유가 법률상 정당한 이유가 있다고 인정하기 위해서는 취소결정을 취소할 만한 명백한 사정이 있을 것을 요한다. 구체적으로는 취소결정의 기초가

된 서증이 위조되었거나 참고인의 진술이 허위진술인 것이 객관적인 근거에 의하여 명백한 경우, 취소결정을 뒤집을 가능성이 있는 서증이 발견되거나 참고인의 진술이 가능하게 된 경우 등이 이에 해당한다.

- 228 (라) 보전처분을 취소함으로써 인하여 채권자에게 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 사정은 효력정지의 재판을 하지 않으면 안 되는 채권자 측의 적극적인 필요성을 의미한다. 구체적으로는 취소결정에 기하여 보전집행의 구속력에서 벗어나면 목적물의 처분 등 현상변경이 생기는 경우, 장래에 다시 보전집행을 할 여지가 없게 되는 경우, 채권자에게 대체물·금전의 급부에 의하여 회복할 수 없는 손해가 발생하는 경우, 건물의 건축금지가처분이 취소되면 건물이 완성되어 철거가 사실상 곤란하게 되는 경우 등이 이에 해당한다.

(마) 효력정지의 요건에 관한 소명은 보증금을 공탁하거나 주장이 진실함을 선서하는 방법으로 대신할 수 없다(민집 289조 2항).

(3) 효력정지재판이 가능한 시기

효력정지재판을 할 수 있는 시기는 즉시항고에 대한 재판이 있을 때까지이지만, 보전집행이 취소된 후에는 취소결정의 효력을 정지할 법률상 이익이 없으므로(대결 1990. 7. 28. 89그22), 보전집행이 취소될 때까지가 시간적 한계가 된다. 따라서 가처분취소결정에 대하여 효력정지의 재판을 하기 전에 가처분취소결정의 집행이 마쳐진 경우에는 효력정지의 재판을 할 수 없고, 가처분취소결정의 집행이 마쳐진 후에 이를 간과하고 효력정지의 재판을 받았다고 하더라도 이미 집행된 가처분등기말소 및 그 이후에 이루어진 제3자 명의의 소유권이전등기의 효력에는 아무런 영향을 미치지 못한다(대결 2009. 3. 13. 2008마1963).

부동산에 대한 가압류·처분금지가처분의 경우 보전집행법원의 법원사무관 등이 말소등기의 촉탁서를 발송할 때까지 채권자는 취소결정의 효력정지결정 정보를 법원에 제출하여야 하고, 효력정지결정이 담보제공조건부인 경우에는 담보를 제공하였음을 증명하는 서면도 아울러 제출하여야 한다.

- 동산에 대한 가처분·점유이전금지가처분에서 집행관이 목적물을 점유하는 방법에 의하여 보전집행이 이루어진 경우에는 집행관이 목적물을 채무자에게 인도할 때 집행취소절차가 완료된다. 목적물을 수취할 수 있는 권리를 가진 자가 목적물을 보관하고 있는 경우에는 229 는 보관자에 대하여 집행취소의 통지를 보낼 때 집행취소절차가 완료된다. 따라서 집행관이 목적물을 인도하거나 통지를 발송할 때까지 효력정지재판을 할 수 있다.

(4) 관할법원

효력정지재판은 항고법원이 하는 것이 원칙이지만, 재판기록이 원심법원에 있는 때에는 원심법원이 효력정지의 재판을 한다(민집 289조 3항).

(5) 효력정지의 재판

효력정지결정을 하는 경우 담보제공여부는 법원의 재량사항으로서, 법원은 담보를 제공 하거나 담보를 제공하지 아니하게 하고 보전처분취소결정의 효력을 정지시킬 수 있다(민집 289조 1항). 법원이 효력정지결정을 명하기 위하여 담보제공명령을 발령하였다면 이러한 담보제공명령은 나중에 있을 재판에 대한 중간적 재판에 해당하는데, 위 명령에서 정한 공탁금액이 너무 과다하여 부당하다고 하더라도 담보제공명령에 대하여는 독립하여 불복할 수 없다(대결 2001. 9. 3. 2001그85). 그러나 효력정지결정은 채무자에게 중대한 영향을 미치므로 담보를 제공하게 하거나 담보제공을 조건으로 발령하는 것이 타당하다. 사정이 급박한 경우에는 재판장이 효력정지결정을 할 수 있다(민집 312조).

효력정지기간은 일반적으로 항고심결정 시까지로 정하는데, 항고심결정확정 시나 본안 판결 선고 시까지로 정하는 경우도 있다. 취소결정의 효력이 정지되면 보전집행의 취소도 정지되고, 부작위를 명하는 가처분에서 취소결정의 효력이 정지되면 채무자는 다시 부작 위 의무를 부담하게 된다. 가처분명령의 취소결정에서 원상회복의 재판이 이루어진 경우에는 채권자는 원상회복의 재판에 한하여 효력정지를 구할 수도 있다.

당사자는 효력정지결정에 대하여 불복할 수 없다(민집 289조 5항).

(6) 항고법원의 효력정지결정에 대한 재판

항고법원은 항고에 대한 재판에서 효력정지재판을 인가·변경 또는 취소하여야 한다(민 집 289조 4항). 위 재판에 대하여는 불복할 수 없다(민집 289조 5항). 그러나 효력정지의 230 기간을 항고심결정 시까지로 정한 경우에는 효력정지재판을 인가·변경·취소할 실익이 별로 없으므로, 위 규정은 보전처분취소결정의 확정 시 또는 본안판결 선고 시까지 효력정지 결정을 한 사안에서 즉시항고가 인용된 경우에 의미가 있다.

마. 재도의 고안

보전처분의의·취소결정에 대하여 즉시항고가 있는 경우에도 원심법원이 항고에 정당한 이유가 있다고 인정하는 때에 그 결정을 경정할 수 있는 이른바 재도의 고안(민집 23조

1항, 민소 446조)을 허용할 것인가가 문제된다. 민사집행법 23조에 의하여 준용되는 민사소송법 446조에 의하여 이를 허용하여야 한다는 견해도 있을 수 있으나, 보전처분이의·취소결정은 당사자 쌍방이 참여할 수 있는 심문기일 또는 변론기일을 거치는 등 판결절차와 유사하게 진행된 후에 이루어지는 점을 감안할 때 재도의 고안은 성질상 인정하기 어렵다.

바. 즉시항고의 취하

즉시항고는 상대방의 동의 없이 취하할 수 있고, 이에 의하여 원재판이 확정된다. 보전처분이의·취소신청의 취하서면을 송달하도록 규정한 민사집행법 285조 4항에 비추어 볼 때, 동일한 절차에 해당하는 이의·취소결정에 대한 즉시항고의 취하에 대하여는 송달의 방법으로 통지함이 상당하다. 즉시항고가 제기된 후에도 채권자는 보전처분신청 자체를 취하할 수 있고, 이 경우에도 상대방의 동의는 불필요하다.

사. 항고사건의 심리

민사집행법은 286조 7항의 즉시항고에 관하여 민사소송법 447조를 준용하지 않는다는 규정을 두고 있을 뿐, 그 절차에 관하여는 아무런 규정도 두고 있지 않다. 따라서 즉시항고
231 의 심리절차에 관하여 민사집행법 286조를 적용하여 변론기일이나 상대방이 참여할 수 있는 심문기일을 지정하고, 심리종결선언을 하여야 하는지 문제된다.

위 문제에 대하여 종래에는 항고심 심리절차에도 민사집행법 286조를 준용하여 변론기일 또는 상대방이 참여할 수 있는 심문기일을 지정하고, 심리종결선언을 하여야 한다는 견해와, 항고심 심리절차에 관하여는 민사집행법 286조가 준용되지 아니하므로 항고심은 임의적 변론·대면심문·서면심리 등 심리방식 중에서 어느 한 방식을 임의로 선택할 수 있다는 견해가 대립하고 있었다.

판례는 “민사집행법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 보전처분 절차에 관하여는 민사소송법의 규정을 준용하는데 민사소송법은 결정으로 완결할 사건에 대하여는 법원이 변론을 열 것인지 아닌지를 정하고, 변론을 열지 아니할 경우에 법원은 당사자와 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다고 규정하고 있다. 그런데 민사집행법은 항고법원의 심리방법에 관하여는 아무런 규정도 두고 있지 않으므로 항고법원의 심리에 관하여는 결정으로 완결할 사건에 관한 민사소송법의 규정이 준용되어 항고법원이 변론을 열 것인지 아닌지 및 변론을 열지 아니할 경우에 당사자와 이해관계인 그 밖의 참고인을 심문할 것인지 아닌지를 정할 수 있다고 보아야 한다.”고 판시하여 후자의 견해를 명시적으로

채택하였다(대결 2012. 5. 31. 2012마300).

항고심은 앞서 본 바와 같이 임의적 변론, 심문, 서면심리 등 심리방식 중에서 어느 한 방식을 임의로 선택할 수 있지만, 실무상으로는 대부분 서면심리만 하고 있다.

하지만 본안이 항소심에 계속 중이어서 항소심법원이 1심으로 보전처분을 발령하고 이에 대하여 채무자가 이의·취소를 제기한 경우 그 보전이의·취소소송, 제1심법원의 보전신청배척재판에 대하여 채권자가 항고를 제기하여 항고법원에서 1심 재판을 취소하고 보전처분을 발령한 후 이에 대하여 채무자가 이의·취소를 제기한 경우 그 보전이의·취소소송에 대하여는 모두 민사집행법 286조가 적용되고, 법원은 변론기일 또는 당사자 쌍방에게 참여할 수 있는 심문기일을 정하고 당사자에게 이를 통지하여야 한다.

아. 보전처분취소결정을 취소·변경한 상급심의 새로운 집행

232

제3편
제6장
제1절

상소법원에서 보전처분취소결정을 취소·변경함으로써 그 보전처분에 관하여 새로운 집행이 필요하게 된 때에는, 법원이 집행기관이 되는 경우에 한하여 절차의 신속을 위하여 취소의 재판을 한 상소법원이 직권으로 그 집행절차를 진행하되, 다만 그 법원이 대법원인 경우에는 채권자의 신청에 따라 제1심법원이 집행한다(민집 298조, 301조). 항고법원에서 보전처분취소결정을 취소하는 경우에도 보전처분을 인가하는 데 그칠 뿐, 다시 보전처분을 발령하지는 않는다. 그러나 보전처분취소결정의 취소결정은 소급효가 없으므로, 보전처분의 재집행 전에 채무자가 피압류물을 처분하는 것을 막으려면 보전처분취소결정에 대한 효력정지결정을 받아야 한다.

자. 소송비용

원칙적으로 법원이 사건을 완결하는 재판을 할 때에는 직권으로 그 심급의 소송비용 전부의 부담에 관한 재판을 하여야 하고(민소 104조), 이러한 재판을 하지 아니한 때에는 재판을 누락한 것이 된다(민소 212조). 민사소송법 104조에서 규정하는 ‘사건을 완결하는 재판’에는 가압류·가처분을 명하는 결정도 포함된다고 해석하는 것이 일반적이다. 따라서 법원은 당사자의 신청 유무에 불구하고 직권으로 소송비용의 재판을 하여야 하므로, 가압류·가처분신청사건이라도 심문이나 변론을 거치는 경우에는 소송비용부담 재판을 하여야 한다. 하지만 심문이나 변론을 거치지 아니하는 가압류·가처분신청사건은 당사자가 보전처분신청과 동시에 소송비용부담의 재판을 신청한 경우라도 소송비용부담의 재판을 할 필요가 없고, 현재 실무상 합의부에서 이루어지는 임시의 지위를 정하는 가처분이나 단행

가처분을 제외한 통상의 가압류·가처분신청사건에서 심문이나 변론을 거치는 경우는 거의 없기 때문에 소송비용부담의 재판이 이루어지는 경우는 없다.

- 233 하지만 보전처분에 대한 이의·취소 사건이나, 보전의의·취소에 대한 항고사건은 실질적으로 서로 대립하는 상대방이 소송에서 자기의 권리신장을 위하여 공격·방어할 수 있는 기회가 보장된 대심적 소송구조에 해당하기 때문에 소송비용부담의 재판을 하여야 한다. 나아가 피항고인이 항고인의 항고취하 전에 변호사를 선임하여 그 변호사가 사건을 검토한 후 주장서면을 제출하는 행위는 위임사무에 해당하므로, 이와 관련하여 지급한 변호사보수는 소송을 수행함에 있어 발생한 비용으로서 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 3조 2항 본문에 따라 소송비용에 산입하여야 한다(대결 2010. 5. 25. 2010마181).

4. 재항고

가. 재항고의 허용 여부

즉시항고에 관한 재판에 대하여 재항고를 할 수 있는지 여부에 관해서는 민사집행법에 아무런 규정이 없으나, 보전소송의 절차에 관하여 민사집행법에 특별한 규정이 없는 경우에는 민사소송법의 규정을 준용하므로(민집 23조 1항), 민사소송법 442조에 의하여 항고법원의 재판에 대하여 재항고를 할 수 있다.

나. 재항고의 성질과 기간

항고법원의 재판에 대한 재항고는 성질상 즉시항고이다. 준용규정은 민사소송법 제3편 제3장이므로, 재항고는 재판이 고지된 날부터 1주 이내에 재항고장을 원심법원에 제출하는 방식으로 제기하여야 한다(민집 23조 1항, 민소 444조 1항, 445조). 재항고장에 재항고이유를 적지 아니한 때에는 재항고인은 대법원의 법원사무관등으로부터 소송기록의 접수통지를 받은 날로부터 20일 이내에 재항고이유서를 제출하여야 한다(민집 23조 1항, 민소 443조 2항, 426조, 427조).

다. 재항고사유

- 234 재항고는 재판에 영향을 미친 헌법, 법률, 명령 또는 규칙의 위반을 이유로 드는 때에만 할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 442조). 따라서 재항고사건에서는 원심의 사실인정이

자유심증주의의 한계를 벗어나는 등 법령에 위반된 점이 있는 경우를 제외하고는 증거의 취사나 사실인정이 잘못되었다는 사유를 재항고이유로 주장하는 것이 허용되지 아니하고, 재항고심에서 사실심리를 새로이 해 달라는 요구 역시 받아들일 수 없다. 그리고 재항고심은 사후심으로서, 원심의 사실인정에 자유심증주의 위반 등 법령 위반이 있는지 여부를 판단하는 것은 원심결정 단계까지 제출된 소송자료를 기초로 하여야 하는 것이고, 원심결정 이후에 제출된 자료를 그 판단의 자료로 삼는 것은 허용되지 않는다(대결 2010. 4. 30. 2010마66).

라. 재항고와 집행부정지의 원칙

재항고의 경우에도 집행부정지의 원칙이 적용된다.

마. 항고법원의 재판에 대한 효력정지

재항고인이 재항고심에서 승소하더라도 집행부정지의 원칙상 재항고의 목적을 달성할 수 없는 경우도 있을 수 있다. 이를 방지하기 위하여 재항고인은 항고법원의 재판에 대하여 효력정지를 신청할 수 있다.

바. 재항고의 이익

가처분결정에 직무집행을 정지하는 기간이 정하여져 있는 경우 그 기간의 경과로 가처분결정의 효력이 상실되므로, 그 기간 경과 후에는 가처분결정이 외형상 존존함으로 인하여 어떠한 법률상 이익이 침해되었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 그 취소를 구할 법률상의 이익이 없다. 따라서 원심결정 이후 직무집행정지기간이 경과한 경우에는 채무자로서는 원심결정에 대하여 더 이상 재항고로 불복할 이익이 없으므로, 재항고는 부적법하다(대결 2013. 6. 17. 2013마568).

제2절 통상항고

민사집행법 281조 2항에 의하면 채권자는 가압류신청을 기각하거나 각하하는 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있고, 같은 법 283조 1항에 의하면 채무자는 가압류결정에 대하

여 이의를 신청할 수 있으며, 같은 법 286조 3, 6항에 의하면 이러한 가압류이의신청에 대한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있도록 하고 있기 때문에, 보전신청에 대하여는 통상항고에 기한 불복절차가 없다.

제3절 특별항고

불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여는 재판에 영향을 미친 헌법위반이 있거나, 재판의 전제가 된 명령·규칙·처분의 헌법 또는 법률의 위반 여부에 대한 판단이 부당하다는 것을 이유로 하는 때에만 대법원에 특별항고를 할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 449조 1항). 그러나 대법원의 결정에 대하여는 특별항고를 할 수 없다(대결 1987. 9. 15. 87그30). 효력정지신청을 기각한 결정(대결 2005. 12. 19. 2005그128), 보전처분경정신청을 기각한 결정(대결 1991. 3. 29. 89그9), 담보물변경결정(대결 2000. 5. 31. 2000그22) 등은 특별항고의 대상이 될 수 있다. 하지만 담보제공명령·인지보정명령 등의 경우에는 불복할 수 없는 명령이기는 하지만 중간재판으로서 이에 대하여는 독립하여 불복하는 것 자체가 불가능하여 특별항고의 대상도 될 수 없다(대결 2001. 9. 3. 2001그85, 대결 2009. 3. 27. 2009그35).

재도의 고안을 허용하는 것은 특별항고를 인정한 취지에 맞지 않으므로, 특별항고가 있는 경우 원심법원은 경정결정을 할 수 없고 기록을 그대로 대법원에 송부하여야 한다(대결 2001. 2. 28. 2001그4).

제4절 도산절차와 보전항고절차

실무에서는 회생절차가 개시된 채무자의 관리인이나 파산선고된 채무자의 파산관재인이 가압류·가처분결정에 대하여 이의 및 항고를 하기보다는 이미 진행된 절차의 외형을 제거하기 위한 집행취소신청을 하는 것이 일반적이기는 하지만, 가압류·가처분결정에 대하여 이의 또는 취소신청을 하고 그 결정에 대하여 항고를 하는 경우 가압류·가처분결정과 도산절차의 선후관계별 항고법원(가압류·가처분이의 사건 재판부 포함)의 처리는 다음과 같다.

관련 도산절차·재판	선후관계	항고법원의 처리
개인회생절차에서 금지명령	금지명령 효력발생 후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 금지명령의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
	금지명령 효력발생 전 가압류·가처분결정	항고(이의)기각, 가압류·가처분결정 유효
회생절차·개인회생 절차개시결정, 파산선고결정 (동시폐지 제외)	개시결정 등 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 개시결정 등의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
	개시결정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)에 대한 재판정지, 이후 회생인가결정·변제계획인가결정 있으면 가압류·가처분 취소
	파산선고결정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 파산선고결정의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
개인파산절차에서 면책신청	면책신청이 있고 파산선고 및 동시폐지결정의 확정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)에 관한 재판 정지, 면책결정 확정되면 가압류·가처분 취소
	면책신청 및 파산폐지결정의 확정 또는 파산종결결정 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 면책재판절차의 계속 효과에 반한 가압류·가처분결정 취소(이후 면책불허가결정이 확정되더라도 마찬가지)
	면책결정 확정 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 가압류·가처분 취소(면책결정의 확정은 집행장에 사유는 아니나, 채권이 자연채무화 되어 보전의 필요성이 없어졌거나, 사정변경이 생겼음을 이유로)

제7장 보전집행

제1절 보전집행의 일반원칙

1. 강제집행 규정의 준용

가압류의 집행에 관하여는 민사집행법 292조 이하 몇 조문의 특칙이 있는 것을 제외하고는 강제집행에 관한 규정을 준용한다(민집 291조, 민집규 218조). 가처분의 집행에 관하여도 같다(민집 301조). 그러므로 보전처분의 성질에 반하지 않고 특칙에서 따로 규정되어 있지 않는 한 보전처분의 집행에 관하여는 강제집행에 관한 규정이 모두 준용된다고 보아도 좋다. 따라서 집행의 목적물, 집행기관, 집행의 방법, 위법집행에 대한 채무자 및 제3자의 구제절차 등은 강제집행에 관하여 설명한 바를 참고하면 된다.

그러나 집행권원의 집행력을 배제하기 위한 제도인 청구에 관한 이의의 소(민집 44조)의 규정은 준용되지 않고, 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 45조)의 규정도 원칙적으로 준용되지 않는다(승계집행문이 있는 경우는 예외). 또한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 중 근로자지위보전가처분과 같은 가처분은 관념적인 법률상태의 조성만을 목적으로 하고 그 이상으로 집행기관의 집행처분은 필요하지 않으므로 강제집행에 관한 규정이 준용될 여지가 없다.

2. 보전집행의 특색

일반적으로 보전집행의 특색은 다음 네 가지로 설명된다.

- 238 ① 보전처분의 집행력은 그 명령 성립과 동시에 발생하고 그 명령의 확정을 기다릴 필요가 없다. 따라서 가집행선고를 불일 여지가 없으며, 보전처분 발령법원이 동시에 집행기관